

경기도 프리랜서 공정 가이드라인



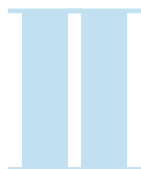


프리랜서 불공정 계약과 현황

프리랜서 불공정 계약의 원인과 현황 ● 06

프리랜서 계약이 활성화되어 있는 대표적 분야들 ● 07

SW프리랜서 불공정 계약의 유형 ● 10



SW 프리랜서 계약체결시 유의사항에 관한 Q&A

계약서를 교부받지 않은 상태에서의 구두계약의 효력 ● 14

계약서 일부사항 미기재의 효력 ● 17

부당한 위탁취소 ● 19

수령거절후 목적물 멸실에 따른 책임 ● 22

프로그램 구매대금의 부당한 산정 ● 24

검수결과 통지 지연 ● 26

목적물에 대한 부당반품 ● 28

검사결과와 부당한 통보 ● 31

기술자료의 부당한 유용 ● 33

재하도급 관련 분쟁 ● 36





계약이행(하도급대금지급) 보증 방법 ● 38

계약 이외의 사항 ● 42

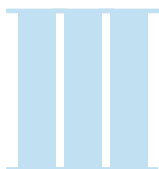
개별약정의 효력 ● 45

손해배상 청구 방법 ● 47

계약 내용 변경 방법 ● 50

하자담보책임 & 손해배상 ● 52

계약의 해제 또는 해지 ● 54



프리랜서들이 겪는 불공정 거래는 어느 법에 위배되나?

주요 규정 ● 58

하도급법 상 불공정행위 금지에 관한 규정 ● 61

부록1 콘텐츠 분야 프리랜서 불공정 사례 ● 64

부록2 거래 시 유의해야 할 점(체크리스트) ● 72

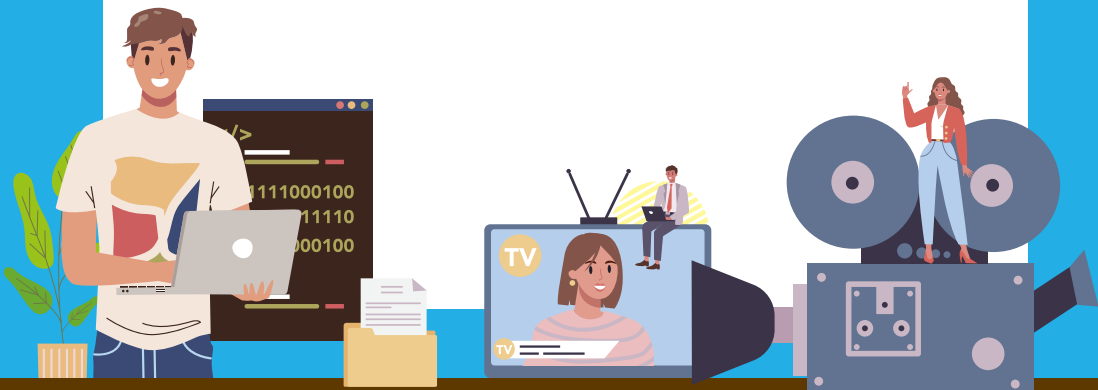


경기도
프리랜서 공정
가이드라인



프리랜서 불공정 계약과 현황

- 프리랜서 불공정 계약의 원인과 현황
- 프리랜서 계약이 활성화되어 있는 대표적 분야들
- SW프리랜서 불공정 계약의 유형



프리랜서 불공정 계약의 원인과 현황

‘프리랜서’는 누군가에 법적으로 종속되어 있지 않다는 점에서 보면 ‘자유직’이라는 뜻으로 읽혀지기도 하지만, 근로자처럼 일하지만 근로자로서 보호받지도 못하고 사용자처럼 자유롭지만 그 만큼의 금전적 보상을 받지도 못하는 경제적 약자다. 그 결과 노동법을 통해 보호받지 못하는 제3의 경제주체가 노동자와 별반 다를 것이 없는 약자적 지위에 처해 있으면서 거래상대방이 우월적 지위에서 행하는 각종 남용행위나 부당한 작업 조건을 강요받는 일들이 빈번히 나타나고 있다.

프리랜서는 근무환경이 반복적, 일상적 업무로 이루어지기 보다는 상황에 따라 선택과 집중이 요구되는 직역에서 등장해 왔으며, 그런 분야로서 대표적인 영역으로는 방송, 문화, 건설 및 소프트웨어 등 IT 산업을 들 수 있다.

특히 소프트웨어(SW)프리랜서는 업무 수행을 위한 계약 체결 시 근로계약과 용역계약(위임, 도급계약 포함) 형태가 가장 선호되는 분야이며, SW프리랜서를 고용하거나, 계약을 체결하는 기업들은 SW프리랜서 입장에서 불합리하고 불공정한 계약을 체결하는 사례가 증가하면서 SW프리랜서의 처우가 보다 악화되고 있다.



프리랜서 계약이 활성화되어 있는 대표적 분야들

프리랜서는 근무환경이 반복적, 일상적 업무로 이루어지기 보다는 상황에 따라 선택과 집중이 요구되는 직역에서 등장해 왔다. 그런 분야로서 대표적인 영역으로는 방송, 문화, 건설 및 정보통신 산업을 들 수 있다.



1990년대 이후 크게 증가한 방송콘텐츠 외주제작과 다단계 하도급 생산으로 인해 취업형태가 다양화하고, 프리랜서 취업자를 다수 이용하는 대표적인 산업이 되었다. 이 과정에서 프리랜서 피디를 비롯한 방송산업의 프리랜서 근로자는 프로그램 제작의 도급계약 또는 위탁계약에 의해 업무를 수주하던 개인 청부업자(자영업자)로 취급되어 피고용자를 대상으로 적용되어 오건 노동권 보장과 사회보험 적용으로부터 배제되는 일들이 빈번히 발생해 왔다.



만화는 창의력을 바탕으로 스토리 개발, 작화 등 작업이 전과정에 걸쳐 창작성이 요구되는 분야로서, 작가나 예술가, 배우 등이 주로 프리랜서 방식으로 계약을 체결해 온 대표적인 분야이다. 최근 들어 만화가 소비되는 플랫폼에도 급격한 변화가 나타나고 있다. 즉 만화의 보급 채널이 종전의 출판 매체에서 인터넷, 모바일 중심으로 전환되면서 시장의 진입이 자유로워지게 되었고 그 결과 프리랜서 만화가의 비율도 급격히 증가하고 있다.



영화는 연출, 제작, 촬영, 조명, 미술 등 다양한 분야의 전문가들이 모여 협업적 환경 속에 작업을 진행하는 산업적 특수성을 가진다. 대개의 경우 영화 제작사들은 작가나 연출, 조명 등 전문가를 소속회사 의 상근 직원으로 채용할 엄두를 내지 못한다. 제작사들의 규모가 대부분 영세한데다 항상 제작 작품이 대기해 있는 것이 아니기 때문이다. 이에 더하여 영화 제작이 제작사 자본이 아니라 제3의 투자자에 의해 이루어진다는 점도 제작에 투입되는 인원 대부분을 프리랜서에 의존하는 요인으로 작용한다.

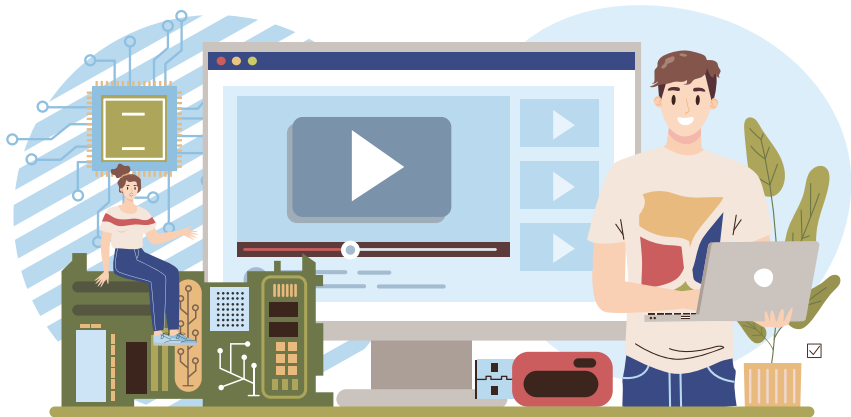


IT 분야는 프리랜서가 폭넓게 활용되는 대표적 분야이다. SW를 비롯한 IT산업에서 프리랜서에 대한 수요가 발생하는 이유는 크게 세 가지 때문이다. 첫째, 개인이 단독으로 창작물을 만들거나 용역을 제공하는 것이 가능한 직종의 경우 프로젝트별로 도급계약을 체결하는 것이 유리하다는 판단에서 프리랜서에 대한 수요가 발생하게 된다. 주로 웹일러스트레이터, 소형 웹사이트 제작에 참여하는 웹디자이너, 컨설팅, 교육을 제공하는 IT컨설턴트 등의 분야에서 흔히 나타나는 프리랜서들이 이 같은 수요에 따른 것으로 볼 수 있다. 둘째, 고도의 기술력을 요구하는 사업이나 정규인력의 기술력으로 해결하기 힘든 분야에서 오히려 프리랜서 고급기술자에 대한 수요가 발생하게 된다. 컴퓨터서비스업 중에서도 솔루션업이나 패키지소프트웨어 개발업 등 기술력 요구 수준이 높은 업종을 예로 들 수 있다. 한편 SI분야에서는 소규모의 하도급업체가 상위 도급업체로부터 용역사업을 수주받는 경우가 생기는데 이 과정에서 용역의 수행을 위해 프리랜서들을 영입하려는 수요가 발생하게 된다. 지역의 소규모 하도급업체들의 경우 자사 정규직의 숫자가 적은 반면 초급 기술자 비율이 높는데 이들이 사업을 하청받으면 자사 정규직만으로는 사업을 수행하

기가 어렵기 때문에 중급 정도의 역량을 갖춘 프리랜서 개발자들을 영입할 필요를 느끼게 되는 것이다.



건설, 공연 등의 산업 분야에서도 프리랜서 활용 빈도가 높게 나타난다. 이들 산업에서는 사업 자체가 꾸준히 향상성을 지니는 것이 아니라, 프로젝트 중심으로 특정 생산물을 완성하는 형태로 이루어지는 경우가 빈번하다. 프로젝트 단위로 사업이 운영되면, 프로젝트 수행 기간 외에 소속 인력을 고용하고 이를 유지하기에 상당한 부담이 뒤따르기 때문에 근로자의 고용 대신 프리랜서를 활용하는 빈도가 높아진다. 이 과정에서 SW프리랜서와 유사한 형태의 불공정 계약이 체결되기도 한다.



SW프리랜서 불공정 계약의 유형

● 서면 보다 구두 방식이 일반화된 계약문화

SW프리랜서들이 업무 수행 시 계약서를 항상 작성하는 비율이 대략 55% 정도이고, 아예 작성을 하지 않는 비율이 5%, 그 외 필요에 따라 하는 경우가 40% 안팎인 것으로 나타난다. 특히 프리랜서 경력 1년 미만일 경우 계약서 미작성 비율이 16%로 전체의 3배 이상이며, SW 분야 자체의 계약서 작성비율도 미흡하지만 경력이 짧을수록 이런 현상이 심화되어 있다.

● 계약의 미이행

SW프리랜서는 사업 구조에서 소위 말하는 ‘을’의 입장에 처해 있어서 계약상대자가 거래상 지위를 이용해 부당한 요구를 하거나, 계약사항을 이행하지 않거나, 계약내용을 일방적으로 변경하더라도 거부하기 어려운 경우가 많다.

● 불명확한 업무 범위

SW프리랜서 도급계약은 구체적인 업무범위를 계약서에 명시하고 이를 기준으로 과업변경 및 추가에 대한 판단을 실시하여야 하지만 대부분의 SW프리랜서 계약의 실제 사례를 살펴보면 구체적인 업무범위를 명시한 계약서가 드문 실정이다.

● 지식재산권 활용 제한

현재 소프트웨어진흥법, 용역계약일반조건 등 관계 법령에서 SW사업을 통해 창출

되는 지식재산권을 원칙적으로 공동소유하도록 규정되어 있지만 대다수의 SW프리랜서 계약서는 계약당사자인 SW프리랜서의 지식재산권 소유를 인정하지 않는다.

● 발주자에 의한 일방적 계약 해석

계약사항과 관련하여 당사자 간 이견이 있을 경우 상호협의 및 분쟁조정기구 활용 등을 통해 공정한 처리가 필요함에도 발주자 일방의 해석에 따르도록 하는 경우들이 있다.

● 발주자의 일방적 계약 해지 권한

계약의 해제, 해지 사유와 해당 권리는 계약당사자에게 공통으로 적용되고 부여되는 사항이나, SW프리랜서 계약 사례를 살펴보면 발주자의 일방적 계약해지가 가능하도록 한 불공정 조항이 다수 존재한다.

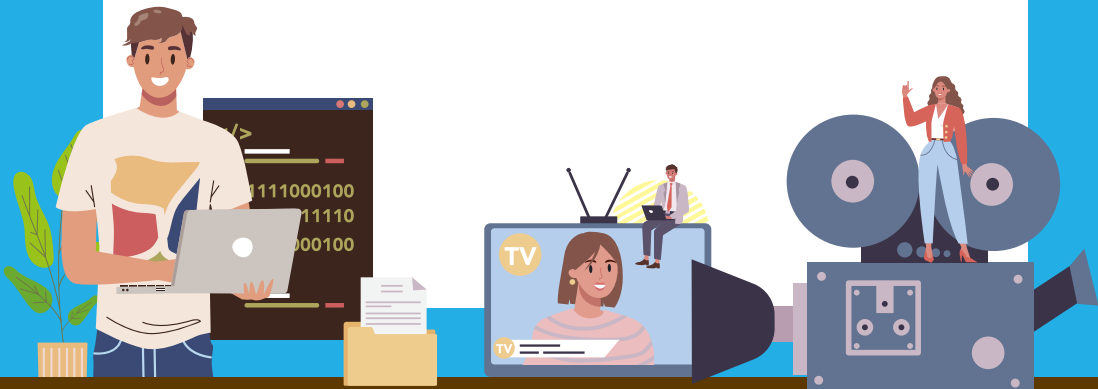


경기도
프리랜서 공정
가이드라인



SW프리랜서 계약체결시 유의사항에 관한 Q&A

- 계약서를 교부받지 않은 상태에서의 구두계약의 효력
- 계약서 일부사항 미기재의 효력
- 부당한 위탁취소
- 수령거절후 목적물 멸실에 따른 책임
- 프로그램 구매대금의 부당한 산정
- 검수결과 통지 지연
- 목적물에 대한 부당반품
- 검사결과와 부당한 통보
- 기술자료의 부당한 유용
- 재하도급 관련 분쟁
- 계약이행(하도급대금지급) 보증 방법
- 계약 이외의 사항
- 개별약정의 효력
- 손해배상 청구 방법
- 계약 내용 변경 방법
- 하자담보책임 & 손해배상
- 계약의 해제 또는 해지



계약서를 교부받지 않고 구두로만 계약했다면?



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')은 프리랜서 △△△(이하 '개발자')에게 소프트웨어 개발을 위탁했습니다. 계약내용은 6개월 이내에 소프트웨어를 개발하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금 3천만원을 지급한다는 것입니다. 다만, 계약은 구두로 체결되었으며, 발주자는 개발자에게 계약서를 교부하지 않았습니다. 이 때 소프트웨어 개발계약을 구두로 체결하였을 경우에 그 계약의 효력이 어떤지요? 소프트웨어 개발계약을 체결한 후 발주자가 계약서를 개발자에게 교부하지 않은 경우에 발주자에게 어떠한 제재가 부과되는지도 궁금합니다.



해설

● 구두계약의 민사적 효력

사례에서 적용되는 하도급법과 상생협력법 상 반드시 서면으로 계약해야 하는 규정이 없기 때문에 구두계약은 유효합니다. 따라서 개발자는 소프트웨어를 개발하여 납품하고, 발주자는 그 대금을 지급하여야 합니다. (단, 국가나 지방자치단체와 계약할 경우 서면계약 준수의무가 있습니다.)

● 사업자에 대한 제재

사례에서 발주자는 개발자와 소프트웨어 개발에 관한 계약을 구두로 체결하고, 계약서를 교부하지 않았습니다. 이는 하도급법 또는 상생협력법 위반에 해당하며, 각

법에 따라 제재를 받게 됩니다. 다만, 하도급법이 적용되기 위해서는 일정한 요건이 충족되어야 하고, 하도급법에 적용되지 않는다면 상생협력법이 적용됩니다.

〈SW개발 관련 하도급법 적용요건〉

- 발주자가 중소기업이 아닌 사업자(ex. 대기업)
- 발주자가 중소기업인 경우 중소기업자인 개발자보다 매출액이 많고, 연간 10억 원 이상의 매출액
- 발주자와 개발자 모두 지식·정보성과물의 작성 또는 직무(役務)의 공급을 업으로 할 것

사례에서 발주자와 개발자는 정보통신업을 영위하는 사업자이기 때문에 3번째의 요건은 충족하였으며, 발주자의 매출액이 개발자(프리랜서)의 매출액이 높다고 가정한다면 사례의 발주자는 하도급법에서 정한 제재(시정명령, 6천만원 이하의 과징금 및 6천만원 이하의 벌금)를 부과받게 됩니다. 반면에 사례에서 발주자의 매출액이 10억원 미만인 경우에 하도급법이 아닌 상생협력법이 적용되며, 발주자에게 시정명령, 벌점, 교육명령, 1천만원 이하의 과태료가 부과됩니다.



관련 법령

● 「하도급거래 공정화에 관한 법률」

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 “추가·변경위탁”이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수

급사업자에게 발급하여야 한다.

4. 용역위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 용역 수행행위를 시작하기 전

☉ 상생협력법

제21조(약정서의 발급) ① 위탁기업이 수탁기업에 물품등의 제조를 위탁할 때에는 지체 없이 그 위탁의 내용, 납품대금의 금액, 대금의 지급 방법, 지급기일, 검사 방법, 그 밖에 필요한 사항을 적은 약정서를 그 수탁기업에 발급하여야 한다.



심결례/판례

☉ 판례[대법원 1995. 6. 16., 선고, 94누10320, 판결]

하도급법 제3조 제1항은 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우에는 하도급대금과 그 지급방법 등 일정한 사항을 기재하고 원사업자와 수급사업자가 기명날인한 서면을 수급사업자에게 교부하도록 규정하고 있는바, 위 규정에 의하면 건설위탁에 있어 원사업자는 건설위탁을 할 때에 수급사업자에게 계약서 등의 서면을 교부하여야 함이 원칙이나 늦어도 수급사업자가 공사에 착수하기 전까지는 이를 교부하여야 할 것이고, 또 당초의 계약내용이 설계변경 또는 추가공사의 위탁 등으로 변경될 경우에는 특단의 사정이 없는 한 반드시 추가·변경서면을 작성·교부하여야 할 것이다.

계약서에 대금관련 사항을 명확히 기재하지 않았다면?



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')(연 매출액 500억원)은 프리랜서 △△△(이하 '개발자')(연 매출액 3억원)와 소프트웨어 개발계약을 체결했습니다. 계약내용은 계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 개발하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금을 지급한다는 것이었습니다. 이후 발주자는 개발자에게 계약서를 교부하였지만, 당시 계약의 대금은 계약서에 기재되지 않았습니다(계약체결 당시 대금에 대해서는 합의하지 않음). 이에 개발자는 서면으로 그 대금을 5천만원으로 한다고 통지하면서 변경할 경우에 협의하겠다는 내용까지 추가하였지만, 발주자는 아무런 답변을 하지 않고 있습니다. 이후 개발자는 소프트웨어를 납품한 후 검사에 통과하여 발주자에게 대금 5천만원을 청구하였지만, 발주자는 일반적으로 개발비가 3천만원이라고 하면서 3천만원만 지급하였습니다.

이 경우 소프트웨어 개발계약의 대금은 얼마로 보아야 하나요?

해설

사례에서 발주자와 개발자는 소프트웨어 개발계약을 체결하고, 발주자는 개발자에게 계약서를 교부하였습니다. 그러나 계약 당시 대금에 대해 합의하지 않았으며, 계약서에 대금이 기재되지 않았습니다. 따라서 개발자는 계약대금(5천만원)에 대한 확인을 요청하였지만, 발주자는 이에 대해 답변을 하지 않았습니다. 이 경우에 하도급법에서는 개발자가 확인요청한 내용대로 계약내용이 결정됨을 규정하고 있으

므로 이 계약에서 대금은 5천만원이 됩니다. 따라서 발주자가 개발자에게 3천만원을 지급한 것은 대금 중 일부만을 지급한 것이며, 나머지 2천만원은 미지급한 것입니다. 이 경우에 2천만원에 대해서는 관련 규정에 따라 산정한 지연이자를 더하여 개발자에게 지급하여야 합니다. 이와 별개로 발주자는 계약서에 필수사항 중 일부가 미기재된 계약서를 교부한 것이기 때문에 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.



관련 법령

◎ 하도급법

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 “추가·변경위탁”이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

4. 용역위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 용역수행행위를 시작하기 전

⑤ 원사업자가 제조등의 위탁을 하면서 제2항의 사항을 적은 서면(제3항에 따라 일부 사항을 적지 아니한 서면을 포함한다)을 발급하지 아니한 경우에는 수급사업자는 위탁받은 작업의 내용, 하도급대금 등 대통령령으로 정하는 사항을 원사업자에게 서면으로 통지하여 위탁내용의 확인을 요청할 수 있다.

⑥ 원사업자는 제5항의 통지를 받은 날부터 15일 이내에 그 내용에 대한 인정 또는 부인(否認)의 의사를 수급사업자에게 서면으로 회신을 발송하여야 하며, 이 기간 내에 회신을 발송하지 아니한 경우에는 원래 수급사업자가 통지한 내용대로 위탁이 있었던 것으로 추정한다.

부당한 위탁계약 취소를 당했다면?



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')(연 매출액 500억원)은 프리랜서 △△△(이하 '개발자')(연 매출액 3억원)와 소프트웨어 제작계약을 체결하였습니다. 계약내용은 계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 제작하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금(5천만원)을 지급하는 것이었습니다. 제작계약에 따라 개발자는 소프트웨어 제작을 착수하였지만, 발주자는 1개월 후에 회사 내부사정으로 소프트웨어 제작이 불필요하게 되었다는 것을 이유로 제작계약을 취소하겠다고 통지하였습니다. 이에 개발자는 이제까지 지출한 비용 및 인건비 등 총 1천만원의 손해에 대한 배상금으로 3천만원을 청구하였지만, 발주자는 회사 내부사정으로 인한 계약취소이기 때문에 손해배상금을 지급할 수 없다고 합니다.

발주자는 소프트웨어 제작계약을 일방적으로 취소할 수 있는 것인지요? 또 이런 경우에 개발자는 발주자에게 손해배상금을 청구할 수 있는지가 궁금합니다.

해설

◎ 계약의 일방적 취소가 가능한지에 관하여

사례에서 발주자는 소프트웨어 제작계약을 체결한 후 일방적으로 계약을 취소(해제)하였습니다. 이러한 해제는 법률에서 인정하지 않은 것이며, 당사자가 합의한 것도 아닙니다. 따라서 발주자의 해제를 정당화할 수 있는 사유가 없기 때문에 하도급법에서 금지하는 부당한 위탁취소에 해당합니다. 그 결과, 발주자의 제작계약

취소는 무효이기 때문에 소프트웨어 제작계약은 여전히 유효합니다. 이와 별개로 발주자의 부당위탁취소는 하도급법을 위반한 행위이므로 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.

☉ 손해배상 청구가 가능한지에 관하여

사례에서 발주자의 부당한 위탁취소에 대하여 개발자는 계약의 존속 또는 손해배상 중 어느 하나 또는 양자 모두를 주장할 수 있습니다. 사례와 같이 개발자가 발주자에게 손해배상을 청구할 경우에 발주자가 지급하여야 할 손해배상액은 그 행위로 인해 발생한 손해만이 아닌 최대 실손해의 3배까지입니다. 따라서 사례에서 개발자에게 발생한 손해가 1천만원이라고 한다면 개발자는 발주자에게 3천만원까지 배상을 청구할 수 있습니다.



관련 법령

☉ 하도급법

제8조(부당한 위탁취소의 금지 등) ① 원사업자는 제조등의 위탁을 한 후 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유가 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁한 경우에는 제2호를 적용하지 아니한다.

1. 제조등의 위탁을 임의로 취소하거나 변경하는 행위
2. 목적물등의 납품등에 대한 수령 또는 인수를 거부하거나 지연하는 행위

제35조(손해배상 책임) ① 원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 원사업자가 제4조, 제8조제1항, 제10조, 제11조제1항·제2항, 제12조의3제3항 및 제19조를 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.



발주자가 부당하게 수령을 거절한 경우 개발자의 책임은?



사례예시

프리랜서 개발자가 소프트웨어 제작을 완료하고 납품일에 이를 발주자에게 납품하고자 하였지만, 발주자는 정당한 이유없이 수령을 거절하였습니다. 이후 개발자의 사무실이 있는 건물에 화재가 발생하여 개발자의 사무실이 모두 불타버렸습니다. 이런 상황에서 개발자는 발주자에게 대금 5천만원을 청구하였지만, 발주자는 이를 거부하고 있습니다.

발주자가 합리적인 사유없이 소프트웨어 수령을 거부한 후 해당 소프트웨어가 멸실(개발자의 책임없는 사유)된 경우에 개발자는 그 대금을 청구할 수 있는지요?



해설

사례에서 발주자는 개발자의 납품에 대해 상당한 이유없이 그 수령을 거절하였으며, 이는 하도급법에서 금지하는 부당한 수령거절에 해당합니다. 따라서 개발자는 하도급법에 따라 손해배상을 청구할 수 있으며, 그 손해의 3배까지 청구할 수 있습니다. 또한 발주자의 수령거절 기간 동안 화재로 인해 개발한 소프트웨어가 멸실되었기 때문에 그에 대한 위험은 발주자가 부담합니다. 따라서 개발자는 발주자에게 대금을 청구할 수 있으며, 다시 소프트웨어를 제작하여 납품할 의무가 없습니다. 이와 별개로 발주자의 부당수령거절행위는 하도급법을 위반한 행위이므로 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.



◎ 하도급법

제8조(부당한 위탁취소의 금지 등) ① 원사업자는 제조등의 위탁을 한 후 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유가 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁한 경우에는 제2호를 적용하지 아니한다.

1. 제조등의 위탁을 임의로 취소하거나 변경하는 행위
2. 목적물등의 납품등에 대한 수령 또는 인수를 거부하거나 지연하는 행위

◎ 민법

제538조(채권자귀책사유로 인한 이행불능) ① 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 채권자의 책임있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다. 채권자의 수령지체 중에 당사자쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 같다.

개발에 필요한 프로그램을 부당하게 비싼 가격으로 팔았다면?



사례예시

계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 제작하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금(5천만원)을 지급하는 내용으로 계약을 체결했습니다. 이 소프트웨어를 제작함에 있어 발주자가 개발하여 판매하는 프로그램이 필요하였으며, 발주자는 다른 사업자에게 판매하는 금액(500만원)보다 2배 높은 1천만원에 개발자에게 판매하였습니다. 이후 개발자가 소프트웨어를 개발하여 납품한 후 발주자는 프로그램 대금 1천만원을 공제한 4천만원만 지급했습니다.

이런 경우에 개발자는 발주자에게 실가보다 2배 높은 가격으로 구입한 프로그램에 대해 발주자에게 손해배상을 청구할 수 있는지가 궁금합니다.



해설

사례에서 발주자는 개발자와 소프트웨어 제작계약을 체결하면서 그 제작에 필요한 프로그램을 자신에게 구입하도록 요구하였으며, 그 프로그램을 다른 사업자에게 판매하는 금액보다 2배 높은 가격으로 판매하였습니다. 이러한 행위는 하도급법에서 금지하는 '제3자에게 공급하는 조건보다 현저하게 불리한 조건으로 구매대금을 지급하게 하는 행위'에 해당합니다. 따라서 수급사업자는 이로 인해 발생한 손해에 대해 원사업자에게 배상을 청구할 수 있습니다.

이와 별개로 발주자의 부당반품행위는 하도급법을 위반한 행위이므로 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.



◎ 하도급법

제12조(물품구매대금 등의 부당결제 청구의 금지) 원사업자는 수급사업자에게 목적물 등의 제조·수리·시공 또는 용역수행에 필요한 물품 등을 자기로부터 사게 하거나 자기의 장비 등을 사용하게 한 경우 정당한 사유 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

1. 해당 목적물등에 대한 하도급대금의 지급기일 전에 구매대금이나 사용대가의 전부 또는 일부를 지급하게 하는 행위
2. 자기가 구입·사용하거나 제3자에게 공급하는 조건보다 현저하게 불리한 조건으로 구매대금이나 사용대가를 지급하게 하는 행위



물품 검수결과와 통지를 지연한 경우



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')(연 매출액 500억원)은 △△△(이하 '개발자')(연 매출액 3억원)와 소프트웨어 제작계약을 체결했습니다. 계약내용은 계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 제작하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금(5천만원)을 지급하는 것이었습니다. 이후 개발자는 소프트웨어 제작을 완료하고 이를 발주자에게 납품했지만 발주자는 다른 업무로 인해 검사가 지연되었다는 것을 이유로 납품일로부터 30일이 지난 후에 검사결과를 불합격으로 통보하였습니다. 이런 경우도 검사결과를 불합격으로 볼 수 있는지요?



해설

사례에서 발주자는 개발자의 목적물 납품에 대한 검사결과(불합격)를 30일 후에 통지하였습니다. 이는 하도급법에서 정한 통지기한을 위반한 것이며, 납품일로부터 10일이 경과한 때에 합격한 것이 됩니다. 다만, 그 통지지연에 대해 정당한 사유가 있다면 이러한 지연통보는 유효하지만, 사례에서는 단지 발주자의 다른 업무를 그 이유로 제시하고 있기 때문에 정당한 사유에 해당하지 않습니다. 따라서 발주자는 개발자에게 대금을 지급하여야 하며, 납품일로부터 60일 이후에 지급한 경우에는 지연이자까지 지급하여야 합니다. 다만, 개발자가 납품한 소프트웨어에 하자가 있는 경우에 발주자는 개발자에게 그 하자의 정도에 따라 하자보수, 계약해제 및 손해배상을 청구할 수 있습니다.

이와 별개로 발주자의 부당반품행위는 하도급법을 위반한 행위이므로 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.



● 하도급법

제9조(검사의 기준·방법 및 시기)

② 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우 외에는 수급사업자로부터 목적물등을 수령한 날[제조위탁의 경우에는 기성부분(既成部分)을 통지받은 날을 포함하고, 건설위탁의 경우에는 수급사업자로부터 공사의 준공 또는 기성부분을 통지받은 날을 말한다]부터 10일 이내에 검사 결과를 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 하며, 이 기간 내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.



발주자가 부당하게 반품을 한 경우



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')(연 매출액 500억원)은 프리랜서 △△△(이하 '개발자')(연 매출액 3억원)와 소프트웨어 제작계약을 체결하였습니다. 계약내용은 계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 제작하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금(5천만원)을 지급하는 것입니다. 개발자는 소프트웨어 제작을 완료하고 이를 발주자에게 납품하였지만, 발주자는 계약에서 정하지 않은 요건이 충족되지 않았다면 반품했습니다. 이에 개발자는 계약에서 정한 요건을 모두 충족하였다는 것을 이유로 대금 5천만원의 지급을 청구하였습니다.

이런 경우에도 발주자가 계약에서 정하지 않은 사유를 이유로 납품한 소프트웨어를 반품할 수 있는 것인지요? 개발자는 발주자에게 손해배상금을 청구할 수 있는지가 궁금합니다.



해설

◎ 반품이 가능한지에 관하여

사례에서 발주자는 개발자가 계약내용에 적합하게 소프트웨어를 제작하여 납품하였음에도 불구하고 계약에서 정하지 않은 검사기준을 적용하여 불합격 통보를 한 후 그 소프트웨어를 반품하였습니다. 이는 하도급법에서 정한 객관적이고 공정한 기준에 따른 검사 의무를 위반한 것이며, 부당한 반품행위에 해당합니다. 따라서 개발자는 위탁받은 사무인 소프트웨어의 제작을 완료한 것이 되며, 발주자는 그 대금

인 5천만원을 지급하여야 합니다.

이와 별개로 발주자의 부당반품행위는 하도급법을 위반한 행위이므로 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.

☉ 손해배상을 청구할 수 있는지에 관하여

수급사업자의 일 완성에 대해 원사업자가 불합격 통보를 하기 위해서는 검사기준이 공정하고 객관적이어야 합니다. 만일 계약에서 정하지 않은 검사기준을 적용하여 불합격통보를 하였다면 이는 하도급법에서 정한 부당한 반품행위에 해당하며, 수급사업자가 계약의 내용에 적합하게 일을 완성하였다면 수급사업자는 자신의 채무를 모두 이행한 것입니다.

따라서 사례에서 발주자의 반품행위는 하도급법에서 금지하고 있는 부당한 반품행위에 해당하기 때문에 개발자는 소프트웨어를 재공급하고, 이에 소요되는 비용과 대금을 발주자에게 청구할 수 있습니다. 만일 발주자가 소프트웨어의 공급을 받은 날로부터 60일을 초과하여 대금을 지급한 경우에 개발자는 대금과 함께 연 15.5%를 곱하여 산정한 지연이자를 청구할 수 있습니다. 또한 발주자의 부당반품으로 인해 손해가 발생한 경우에 개발자는 그 손해의 3배까지 청구할 수 있습니다. 다만, 발주자는 반드시 손해의 3배에 해당하는 금액 전부를 배상하는 것은 아니며, 법원에서 제반사정을 고려하여 그 손해배상액을 결정합니다.



관련 법령

☉ 하도급법

제9조(검사의 기준·방법 및 시기) ① 수급사업자가 납품등을 한 목적물등에 대한 검사의 기준 및 방법은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 객관적이고 공정·타당하게 정하여야 한다.

제10조(부당반품의 금지) ① 원사업자는 수급사업자로부터 목적물등의 납품등을 받은 경우 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없으면 그 목적물등을 수급사업자에게 반품(이하 “부당반품”이라 한다)하여서는 아니 됩니다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.



검사결과와 부당한 통보



사례예시

프리랜서 개발자는 소프트웨어 제작을 완료하고 이를 발주자에게 납품하였지만, 발주자는 소프트웨어의 하자를 이유로 불합격통보를 하였습니다. 그런데 개발자가 그 하자를 조사한 결과, 그 하자는 발주자가 사용하도록 제공한 프로그램에서 발생한 것이었습니다.

발주자가 사용하도록 제공한 프로그램의 하자로 인한 소프트웨어 하자의 경우에 발주자의 불합격통보는 정당한 것인지요?

해설

사례에서 발주자는 개발자가 납품한 소프트웨어에 대해 불합격으로 검사결과를 통보하였지만, 그 하자는 발주자가 사용하도록 제공한 프로그램의 하자로 인해 발생한 것입니다. 따라서 이 경우에 발주자의 불합격통보는 위법한 것이 되어 검사결과는 합격으로 인정됩니다.

다만, 개발자의 하자담보책임(하자보수, 계약해제 또는 손해배상 등)은 개발자의 악의 또는 선의에 따라 달라진다. 먼저, 개발자가 그 프로그램의 하자를 알지 못한 경우(선의)에 그 소프트웨어에 대해 하자담보책임을 부담하지 않습니다. 그 다음으로 개발자가 그 프로그램의 하자를 알고 발주자에게 그 사실을 통지하였음에도 불구하고 발주자가 별도의 지시를 하지 않은 경우 또는 그 프로그램의 사용을 지시한 경우에 개발자는 하자담보책임을 부담하지 않습니다. 그러나 개발자가 그 사실을 통

지하지 않고 그 프로그램을 사용하여 소프트웨어를 제작하였다면 하자담보책임을 부담합니다.

또한 발주자의 부당한 불합격통보로 인해 개발자가 손해를 입은 경우에 개발자는 실손해의 3배까지 배상을 청구할 수 있습니다. 그리고 이러한 행위는 하도급법 위반에 해당하여 발주자는 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 1억원), 벌금(최대 1억원)을 부과받게 됩니다.



◎ 하도급법

제10조(부당반품의 금지) ① 원사업자는 수급사업자로부터 목적물등의 납품등을 받은 경우 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없으면 그 목적물등을 수급사업자에게 반품(이하 “부당반품”이라 한다)하여서는 아니 됩니다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당반품으로 본다.

1. 거래 상대방으로부터의 발주취소 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 목적물등을 반품하는 행위
2. 검사의 기준 및 방법을 불명확하게 정함으로써 목적물등을 부당하게 불합격으로 판정하여 이를 반품하는 행위
3. 원사업자가 공급한 원재료의 품질불량으로 인하여 목적물등이 불합격품으로 판정되었음에도 불구하고 이를 반품하는 행위
4. 원사업자의 원재료 공급 지연으로 인하여 납기가 지연되었음에도 불구하고 이를 이유로 목적물등을 반품하는 행위

개발자의 기술자료를 발주자가 부당하게 유용하였다면?



사례예시

○○○ 정보통신(이하 '발주자')(연 매출액 500억원)은 프리랜서 △△△(이하 '개발자')(연 매출액 3억원)와 소프트웨어 제작계약을 체결하였습니다. 계약내용은 계약일로부터 6개월 내에 소프트웨어를 제작하여 납품하고, 검수가 완료된 날로부터 1개월 이내에 대금(1억원)을 지급하는 것입니다. 이후 개발자는 소프트웨어 제작을 완료하고 이를 발주자에게 납품하였지만, 발주자는 소프트웨어의 유지·보수를 위해 개발자의 기술자료를 요구하였습니다. 이에 개발자는 납품한 소프트웨어의 유지·보수에만 사용하는 것을 조건으로 기술자료를 제공하였지만, 발주자는 그 기술자료를 이용하여 다른 소프트웨어를 제작하였습니다.

이런 경우에 개발자는 발주자의 기술자료 사용금지를 청구할 수 있는지요? 발주자의 기술자료 유용으로 인해 개발자의 손해가 50억원으로 산정되었을 경우에 개발자가 발주자에게 청구할 수 있는 손해액은 얼마인지도 궁금합니다.

해설

◎ 기술자료의 사용금지 청구가 가능한지에 관하여

사례에서 발주자는 개발자의 기술자료를 제공받아 자신의 소프트웨어를 제작함에 있어 활용하였습니다. 이는 하도급법에서 금지하는 기술자료유용에 해당합니다. 다만, 하도급법에서는 발주자의 위법행위에 대한 금지청구를 규정하고 있지 않으며, 공정거래법상 금지청구는 2021년 12월 30일부터 시행되기 때문에 아직 개정

법 시행전이므로 그 금지를 청구할 수 없습니다. 그러나 그 기술자료가 특허법 또는 실용신안법상 특허발명 또는 고안에 해당할 경우에 개발자는 특허법 또는 실용신안법에 따라 발주자의 유용행위를 금지할 수 있습니다. 또한 이에 해당하지 않더라도 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당할 경우에 개발자는 발주자의 유용행위를 금지할 수 있습니다.

☉ 손해배상 청구금액에 관하여

사례에서 발주자의 기술자료유용으로 손해를 본 개발자는 그 손해액이 50억원일 경우에 최대 150억원까지 배상을 청구할 수 있습니다. 물론 이 금액 전부에 대해 발주자가 배상책임을 부담하는 것은 아니며, 법원이 피해규모 및 이로 인해 얻은 이익 등을 감안하여 배상액을 결정합니다. 이와 별개로 발주자는 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 2억원), 벌금(최대 2억원)을 부과받게 됩니다.



☉ 하도급법

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 됩니다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어

느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위
2. 제3자에게 제공하는 행위

☉ 특허법

제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

☉ 실용신안법

제30조(「특허법」의 준용) 실용신안권자의 보호에 관하여는 「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2 및 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.

☉ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등) ① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

재하도급 관련 분쟁



사례예시

계약서에 제작할 소프트웨어 중 일부에 대해 발주자가 지정한 하수급인에게 하도급 하는 내용이 포함되어 있었습니다. 이후 프리랜서 개발자는 소프트웨어 제작을 완료하고 이를 발주자에게 납품하였지만, 발주자는 소프트웨어의 하자를 이유로 불합격통보를 하였습니다. 개발자가 그 하자를 조사한 결과, 그 하자는 발주자가 지정한 재하수급인이 제작하여 납품한 프로그램(발주자가 검사하여 합격통보 함)에서 발생한 것이었습니다. 발주자가 지정한 재하수급인의 프로그램의 하자로 인한 소프트웨어 하자의 경우에 발주자의 불합격통보는 정당한 것인지가 궁금합니다.



해설

사례에서 발주자는 개발자가 납품한 소프트웨어에 대해 불합격으로 검사결과를 통보하였지만, 그 하자는 발주자가 지정한 하수급인의 프로그램의 하자로 인해 발생한 것입니다. 따라서 이 경우에 발주자의 불합격통보는 위법한 것이 되어 검사결과 는 합격으로 인정됩니다. 다만, 개발자의 하자담보책임(하자보수, 계약해제 또는 손해배상 등)은 개발자의 악의 또는 선의에 따라 달라진다. 먼저, 개발자가 하수급인의 부적당함을 알지 못한 경우(선의)에 그 소프트웨어에 대해 하자담보책임을 부담하지 않습니다. 그 다음으로 개발자가 하수급인의 부적당함을 알고 발주자에게 그 사실을 통지하였음에도 불구하고 발주자가 별도의 지시를 하지 않은 경우에 개발자는 하자담보책임을 부담하지 않습니다. 그러나 개발자가 그 사실을 통지하지 않

고 그 프로그램을 사용하여 소프트웨어를 제작하였다면 하자담보책임을 부담합니다. 또한 발주자의 부당한 불합격통보로 인해 개발자가 손해를 입은 경우에 개발자는 실손해의 3배까지 배상을 청구할 수 있습니다. 그리고 이러한 행위는 하도급법 위반에 해당하여 발주자는 하도급법에 따라 시정조치명령, 과징금(최대 2억원), 벌금(최대 2억원)을 부과받게 됩니다.



◎ 하도급법

제10조(부당반품의 금지) ① 원사업자는 수급사업자로부터 목적물등의 납품등을 받은 경우 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없으면 그 목적물등을 수급사업자에게 반품(이하 “부당반품”이라 한다)하여서는 아니 됩니다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

계약이행(하도급대금지급) 보증 방법



사례예시

상용소프트웨어의 개발 및 유지·관리를 전문적으로 하는 업체입니다. 최근에 수주한 사업의 규모가 커서 프리랜서 개발자에게 소프트웨어 및 시스템 구축 업무의 일부를 위탁하는 내용으로 계약을 하려고 합니다. 프리랜서 개발자와 계약을 하다 보니 용역수행의 안정성을 위해 계약이행 보증을 하고 싶습니다. 이와 관련한 방법과 유의사항 등에 관하여 알고 싶습니다.



해설

「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서는 건설하도급과 관련하여 계약이행 및 대금지급보증에 관한 규정(제13조의2)을 두고 있으나, 소프트웨어하도급과 관련해서는 별도의 명시적 규정이 없습니다. 그러나 소프트웨어 하도급 계약의 보증과 관련하여 「소프트웨어사업 표준하도급 기본계약서」 제35조와 제36조에서는 원사업자가 수급사업자에게 계약의 담보를 위해 요구할 수 있는 계약이행보증금과 원사업자의 요구에 상응하여 수급사업자에게 인정되는 하도급대금지급보증 관련 내용을 담고 있습니다. 즉, 원사업자가 계약이행보증금을 요구하는 경우, 수급사업자는 현금 또는 보증서, 사채(국채, 지방채), 예금증서 등 중 하나를 제출해야 합니다. 다만, 원사업자가 하도급대금지급보증을 하지 않거나 대금지급보증이 면제된 경우에는 그렇지 않습니다. 따라서 상담인이 계약이행의 보증을 원하시는 경우, 개발자에게 하도급대금지급을 보증해 주어야 합니다.

하도급대금지급 보증금액은 계약 기간에 따라 약간의 차이가 있으며, 보증이 필요하지 않거나 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 면제할 수도 있습니다. 예를 들어, 하도급대금이 1천만원 이하인 경우 또는 발주자가 직접 하도급대금을 지급하는 경우와 하도급대금의 지급을 전자적으로 관리하기 위한 시스템을 활용하여 발주자가 수급사업자에게 하도급대금을 지급하는 경우가 여기에 해당합니다. 따라서 상담인은 먼저 수급사업자에게 계약이행보증금을 요구하시고, 위에서 제시한 면제 사유에 해당하지 않는다면 하도급대금지급 보증을 해주시면 됩니다. 보증요율은 발주자와 원사업자인 상담인 간 계약에서 정한 요율을 초과할 수는 없으며, 원사업자의 고의 또는 과실로 수급사업자가 보증서의 제출을 지연한 경우에는 수급사업자에게 책임을 물을 수는 없으니 유의하시기 바랍니다.



관련 법령

◎ 하도급법

제13조의2(건설하도급 계약이행 및 대금지급 보증) ① 건설위탁의 경우 원사업자는 계약체결일부터 30일 이내에 수급사업자에게 다음 각 호의 구분에 따라 해당 금액의 공사대금 지급을 보증하고, 수급사업자는 원사업자에게 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액의 계약이행을 보증하여야 한다. 다만, 원사업자의 재무구조와 공사의 규모 등을 고려하여 보증이 필요하지 아니하거나 보증이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

◎ 하도급법 시행령

제8조(건설하도급 계약이행 및 대금지급 보증) ① 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 원사업자가 수급사업자에게 건설위탁을 하는 경우로서 1건 공사의 공사금액이 1천만원 이하인 경우
2. 삭제
3. 하도급계약 체결일부터 30일 이내에 법 제14조제1항제2호(발주자의 하도급대금 직접지급)에 따른 합의를 한 경우
4. 하도급대금의 지급을 전자적으로 관리하기 위하여 운영되고 있는 시스템(이하 “하도급대금지급관리시스템”이라 한다)을 활용하여 발주자가 원사업자 명의의 계좌를 거치지 아니하고 수급사업자에게 하도급대금을 지급하는 경우

「소프트웨어 진흥법」

제61조(소프트웨어공제조합의 설립) ① 소프트웨어사업자는 상호협동과 자율적인 경제활동을 도모하고 소프트웨어산업의 건전한 발전을 위하여 과학기술정보통신부장관의 인가를 받아 각종 자금대여와 보증 등의 사업을 하는 소프트웨어공제조합을 설립할 수 있다

제62조(공제조합의 사업) 공제조합은 다음 각 호의 사업(이하 “공제사업”이라 한다)을 한다.

－생략－

3. 소프트웨어사업에 따른 의무 이행에 필요한 이행보증

심결례/판례

- (1) (주)엘아이지시스템은 4개의 수급사업자에게 정보통신공사 등을 건설위탁하면서 하도급대금 지급보증의무 면제사유가 없음에도 불구하고, 하도급대금의 지급을 보증하지 않았고, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조의2와 동법 시행령

제8조 위반으로 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금 120,000,000원을 부과받았다. <공정거래위원회 의결 제2015-325호(2015.9.22.) 2014건하 2816>

- (2) 대우정보시스템(주)은 수급사업자인 대신네트웍스(주) 등 7개 수급사업자에게 통신설비공사 등을 위탁하면서 해당 하도급대금의 지급을 보증하여야 함에도 불구하고 15개 공사를 진행하면서 건설하도급 대금지급 보증을 하지 않았고, 이에 공정거래위원회는 대우정보시스템(주)에 하도급법 위반을 이유로 하도급법과 관련된 제도 내용에 대한 교육이수명령 등 시정명령을 내렸다. <공정거래위원회 의결 제2008-151호(2008.5.26.) 2007하개2839>



계약 이외의 사항



사례예시

컴퓨터 소프트웨어 납품업체입니다. 얼마 전 소프트웨어 개발업체와 소프트웨어 개발 하도급 계약을 진행하게 되었습니다. 해당 기업에 대한 평판에서 품질에 조금 문제가 있다고 하여 신경이 쓰이긴 하였으나, 전반적인 조건이 괜찮아서 계약은 마친 상태입니다. 혹여 발생할 품질 관련 문제를 사전에 예방하기 위하여 저희 쪽에서 품질 점검의 목적으로 불시에 수급사업자의 생산시설, 생산인력을 확인하는 조항을 계약서에 포함시키려 하는데 문제의 소지가 있을지 궁금합니다.



해설

「약관의 규제에 관한 법률」 제4조에 의하면, 약관에서 정하고 있는 사항에 관하여 당사자 간 내용을 다르게 합의한 경우에는 개별약정의 우선 원칙에 따라 합의한 내용이 약관보다 우선 적용됩니다. 따라서 품질 점검에 대한 사항을 계약서에 명시하는 등 원사업자와 수급자 간의 개별적인 합의를 통해 계약체결을 진행하는 것은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」상 문제는 없습니다. 그러나 합의를 통하지 않고 원사업자인 상담인이 임의로 수급사업자의 사업장을 출입하거나 생산시설 등에 대한 점검은 부당한 경영간섭 또는 품질과 직접적인 연관이 없는 사항에 대해 점검을 하는 경우에는 부당한 기술자료제공요구에 해당할 수도 있습니다. 「소프트웨어사업 표준하도급 기본계약서」 제39조에 의하면, 원사업자는 수급사업자의 경영에 간

섭하는 행위나 경영상의 정보를 요구하는 행위에 대해 금지하고 있습니다. 만일 계약서에는 기재를 하지만 실제로는 적용한 적이 없다고 하더라도 하도급법 제3조의4에서 규정하고 있는 부당한 특약에 해당할 수 있으니 주의를 하여야 합니다.



● 「약관의 규제에 관한 법률」

제4조(개별 약정의 우선) 약관에서 정하고 있는 사항에 관하여 사업자와 고객이 약관의 내용과 다르게 합의한 사항이 있을 때에는 그 합의 사항은 약관보다 우선한다.

제6조(일반원칙) ① 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항은 무효이다.

② 약관의 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 공정성을 잃은 것으로 추정됩니다.

1. 고객에게 부당하게 불리한 조항
2. 고객이 계약의 거래형태 등 관련된 모든 사정에 비추어 예상하기 어려운 조항
3. 계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 계약에 따르는 본질적 권리를 제한하는 조항

● 「하도급거래 공정화에 관한 법률」

제3조의4(부당한 특약의 금지) ① 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 “부당한 특약”이라 한다)을 설정하여서는 아니 됩니다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 부당한 특약으로 본다.

1. 원사업자가 제3조 제1항의 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구함에 따라 발생

된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정

2. 원사업자가 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
3. 원사업자가 입찰내역에 없는 사항을 요구함에 따라 발생한 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
4. 그 밖에 이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정

계약에서 정하지 않은 사항을 요구하는 경우



사례예시

플랫폼 어플리케이션을 배포 및 운영하는 회사입니다. 최근에 새로운 어플리케이션 개발을 위해 업무위탁영역을 발주하여 선정된 소프트웨어 개발업체와 하도급계약을 맺었습니다. 기존의 형식을 통일하기 위해서 수급사업자에게 저희가 보유하고 있는 개발 프로그램을 이용하게 하거나 저희의 제휴고객사를 소개해 주어 업무를 진행 하려고 합니다. 아니면 기존에 사용하고 있던 프로그램을 변경할 때는 저희 쪽의 승인을 받도록 하려고 하는데 하도급법에 저촉이 되는지 궁금합니다.

해설

계약에서 정한 것 이외의 사항에 대해서는 관련 법령의 강행법규에서 정한 바에 따르게 되어있으며, 그 이외의 사항에 대해서는 원사업자와 수급사업자 간의 합의를 통해 정해야 합니다. 또한, 계약 이외의 사항인 만큼 최초 계약 시 견적을 내거나 입찰 참여를 요청하는 때에 본 사안에서와 같이 기존 프로그램의 사용, 제휴사와의 협업, 원사업자의 승인하에 프로그램 변경 등 해당 사항을 명확히 밝혀야 합니다. 「소프트웨어사업 표준하도급 기본계약서」에 따르면, 원사업자는 수급사업자에게 계약서 등에 기재되지 아니한 사항을 요구하거나 입찰내역에 없는 사항을 요구하여 비용을 발생하게 하는 약정에 대하여 무효로 규정하고 있습니다. 이러한 행위는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정하는 부당한 특약에 해당하여 제재조치를 받을 수도 있습니다. 또한, 목적물 등에 대한 품질의 유지·개선 등 정당한 사

유가 없음에도 구매업체를 지정하는 것은 부당한 경영간섭에 해당합니다. 본 사례에서는 계약 체결 후에 부당한 특약 내지 경영간섭에 소지가 있으므로 수급사업자와의 합의를 통해 조율해야 할 것입니다.



손해배상 청구 방법



사례예시

소프트웨어 개발을 하는 프리랜서입니다. OO협회가 발주한 데이터베이스 및 소프트웨어 개발 용역에서 선정된 A업체로부터 소프트웨어 개발 부분을 맡기로 하는 하도급계약을 맺었습니다. 개발 완료 후 납품까지 마쳤는데, 일부 시스템이 미흡하다는 이유로 수정 작업이 완료되지 않을 때까지 대금을 지급할 수 없다고 합니다. 요구에 따라 10여 차례 수정 작업을 하고, 검수를 요청하였으나 승인을 해주지 않고 대금 지급을 거부하고 있습니다. 이 경우 부당한 대금 지급 지연에 대한 손해배상책임을 물을 수 있는지 궁금합니다.

해설

「소프트웨어 표준하도급 기본계약서」 제42조에 따라, 원사업자 또는 수급사업자가 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에 배상책임이 인정됩니다. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제35조에서도 본 사안에서와 같이 원사업자가 하도급법 위반으로 손해를 입힌 경우에는 그에 따른 배상책임을 인정하고 있습니다. 원사업자의 채무불이행 또는 불법행위로 인한 민법상 손해배상책임을 물을 수도 있습니다만, 민법에서 규정하고 있는 손해배상책임을 묻기 위해서는 수급사업자인 상대방이 원사업자의 고의나 과실이 있었다는 점을 입증하여야 합니다. 하도급법에서는 피해자를 보다 두텁게 보호하고, 위반행위를 억제하고자 고의나 과실이 없었다는 점을 원사업자가 입증하도록 규정되어 있습니다. 따라서, 상대방에게는 하도급법에 의한 손해배상책임을 고려하는 편이 유리합니다.

본 사안은 제조물공급계약으로 보수의 지급시기에 관하여 당사자의 특약이나 관습이 없으면 원사업자는 완성된 목적물을 인도받음과 동시에 수급사업자에게 보수를 지급하는 것이 원칙입니다. 목적물의 검수 규정이 있는 경우에도 “목적물이 계약의 내용대로 완성되었는지 여부”를 기준으로 용역비 청구를 할 수 있습니다. 상담인께서는 원사업자로부터 10여 차례 수정 요구를 받고, 그에 따라 용역 작업물을 수정 하였습니다. 이러한 상황은 당초 계약에서 예정된 업무가 최후 공정까지 일단 종료하고 그 주요 부분이 약정된 대로 개발되어 용역계약의 내용대로 일이 완성되었으나, 목적물에 하자가 있는 경우로, 상담인께서는 원사업자가 검수를 거부하더라도 대금 지급을 청구할 수 있습니다. 또한, 대금 지급에 대한 지연이자도 청구 가능합니다.



● 민법

제390조(채무불이행과 손해배상) 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.

제664조(도급의 의의) 도급은 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

제750조(불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

● 「하도급거래 공정화에 관한 법률」

제9조(검사의 기준·방법 및 시기) ② 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우 외에는 수급사업자로부터 목적물 등을 수령한 날부터 10일 이내에 검사 결과를 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 하며, 이 기간 내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에

합격한 것으로 본다.

제35조(손해배상 책임) ① 원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.



계약 내용 변경 방법



사례예시

기업의 보안 솔루션과 서비스를 제공하는 ICT기업입니다. 소프트웨어 개발과 전산 시스템 구축을 위해 30여 회사에 업무를 위탁하여 진행하고 있습니다. 그런데, 예상보다 과업 범위가 크게 늘어나면서 비용과 시간이 더 소모될 것 같습니다. 이에 계약 내용의 일부를 변경해야 할 것 같은데, 방법과 절차가 어떻게 되는지 궁금합니다.



해설

소프트웨어 개발 계약은 비대체물 도급계약의 성질을 띠므로, 별도의 합의 없이 과업 범위를 추가할 경우, 수급인에게 이를 이행할 의무는 없습니다. 「소프트웨어 표준도급 기본계약서」 제41조에서는 합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우, 원사업자와 수급사업자는 상호 합의하여 계약의 내용을 서면으로 변경할 수 있다고 규정되어 있습니다. 따라서 원사업자는 먼저 수급사업자와 서면을 통한 합의를 하여야 합니다. 만일 합의가 이루어지지 않고, 그대로 추가 과업 범위를 진행할 경우, 수급사업자 측에서 계약 내용의 중요한 부분에 착오를 이유로 계약을 취소하거나, 수급사업자의 귀책사유 없이 계약 성립 당시 그 계약의 기초가 되었던 과업 범위라는 객관적 사정이 변경된 것이므로 사정 변경에 의해 계약을 해제할 수도 있습니다. 따라서 수급사업자와의 원만한 합의를 하는 것이 가장 중요합니다.

「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서는 원사업자가 수급사업자에게 제조 등을 위탁하거나, 위탁 후에 해당 계약 내용에 없는 제조 등의 위탁 또는 계약 내용을 변경하는 위탁을 하는 경우에는 동법 시행령 제3조에서 정하고 있는 위탁 목적물, 납품 장소 및 시기, 하도급대금의 지급방법과 지급기일 등의 사항을 서면으로 기재하여 수급사업자에게 발급하도록 되어 있습니다. 또한, 하도급법 제16조에서는 설계변경 등으로 발주자와 원사업자 간 도급금액이 조정된 경우, 원사업자는 발주자로부터 증액 또는 감액받은 날로부터 15일 이내에 그 사유와 내용을 수급사업자에게 통보하도록 규정하고 있습니다. 이러한 절차를 따르지 않는 경우에는 하도급법 위반의 소지가 있으므로 반드시 정해진 기간 내에 서면을 통해 계약 내용의 변경을 해야 합니다.



하자담보책임 & 손해배상



사례예시

소프트웨어 프로그램 개발을 위탁하는 업체입니다. 얼마 전 프리랜서 소프트웨어 개발자에게 업무를 위탁하였습니다. 업무의 내용이 많은 것도 아닌데 작업을 차일피일 미루더니, 계약 기간 내에 개발을 완료하지 못하였습니다. 심지어 개인적인 사유를 들어 한 달 이상 개발을 중단한 적도 있습니다. 이후 개발자가 납품한 소프트웨어 프로그램에 하자가 발견되었고, 이에 수정을 요구하자 기존 40% 가량 완성된 프로그램을 모두 삭제하고 처음부터 다시 개발을 하겠다면서 일정을 임의로 지연시키고는 제 탓을 하고 있습니다. 이 경우에 제가 취할 수 있는 조치는 무엇인가요?



해설

소프트웨어 프로그램 개발 계약의 법적 성질은 민법상 도급계약에 해당합니다. 소프트웨어 프로그램의 경우, 비대체물의 제작으로 도급의 성질을 가지며, 본 사안에서 계약 당사자는 계약에 의하든 혹은 민법상 도급의 법리에 따른 권리·의무를 가집니다. 민법의 규정에 따라, 수급인은 도급인에 대하여 하자담보책임을 부담하며, 그 내용으로는 하자보수청구권, 손해배상청구권, 계약 해제권이 있습니다. 「소프트웨어사업 표준도급 기본계약서」 제44조에서 원사업자는 검사를 마친 날로부터 일정 기간 동안 수급사업자의 개발 등으로 인해 발생한 하자에 대해 상당한 기간을 정하여 하자의 보수를 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 하자보수 기간에 대하여 「소프트웨어 진흥법」 제60조에서는 소프트웨어의 하자담보기간은 1년으로 정

하고 있습니다. 또한, 용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규) 제58조에서는 소프트웨어 하자발생에 따른 조치 이상의 요구는 하자담보책임 범위를 초과한 사항으로 기능개선요구, 최신버전 무상 업그레이드 등 유지관리에 해당하는 사항은 하자담보책임의 범위에서 제외하고 있습니다.

도급계약에서의 하자란 완성된 일이 계약에서 정한 내용대로 이행되지 않고, 그 결과물에 사용가치 또는 교환가치를 감소시키는 결함이 있는지 또는 당사자가 미리 정한 성질을 가지지 못하는 등의 결함을 가진 것으로 볼 수 있는지 여부를 기준으로 합니다. 따라서, 개별 사안마다 당사자 사이에 합의된 계약 내용이 무엇인지 살펴보는 것이 중요합니다. 다만, 소프트웨어 프로그램 개발의 특성상 개발 과정에서 사소한 버그가 생기는 것은 불가피하므로, 모든 버그를 일률적으로 하자라고 단정 지을 수는 없습니다. 통상적인 업무나 기능이 제대로 작동되지 않는 경우 등과 같이 중대한 버그는 하자에 해당한다고 볼 수 있습니다. 프리랜서 개발자의 소프트웨어 프로그램에 하자가 있는 경우, 상담인은 원칙적으로 하자보수청구권을 중심으로 하는 담보책임을 물어 동시이행의 항변권을 행사함으로써 개발자에게 하자부분의 보수 또는 그에 갈음하는 손해배상의 제공이 있을 때까지 대금의 지급을 거절할 수 있습니다. 만일 소프트웨어 프로그램의 하자의 정도가 중대하여 보완이 불가하거나 상당한 기간 내에 보완 또는 수정 작업으로 해결할 수 없어 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 계약을 해제할 수도 있습니다. 이와 더불어 채무불이행으로 인한 손해배상책임을 물을 수도 있습니다.

계약의 해제 또는 해지



사례예시

애플리케이션 소프트웨어를 개발하는 업체입니다. 얼마 전 모바일 게임 애플리케이션 개발업체인 A사와 소프트웨어를 납품하기로 하는 계약을 체결한 후, 작업을 진행하였습니다. 그런데, A사에서 계약한 업무 외의 사항에 대해 수차례 요구하였고, 이로 인해 개발 일정이 지연되었습니다. 그러자 오히려 A사에서 계약상 약정 기한이 도래하였다는 이유로 일방적으로 계약 해지를 통보하였습니다. 이 경우에 어떻게 해야 하나요?



해설

「소프트웨어사업 표준하도급 기본계약서」 제45조에서는 계약의 해제와 해지에 대한 내용을 담고 있는데, 원사업자와 수급사업자는 일정한 요건에 따라, 서면으로 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있습니다. 즉, 원사업자 또는 수급사업자의 거래정지처분, 영업정지, 파산 등 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우에는 즉시 해제 또는 해지가 가능합니다. 또한, 원사업자 또는 수급사업자가 계약상의 중요한 의무를 이행하지 않거나, 원사업자가 상용소프트웨어의 개발에 필요한 사항의 이행을 지연하여 개발에 지장을 초래한 경우, 수급사업자가 개발을 거부하거나 지연하여 기한 내에 개발이 불가능하다고 객관적으로 인정되는 등의 사유가 발생한 경우에는 1개월 이상의 기간을 정하여 서면으로 이행을 최고하고, 기간 내에 이행하지 않으면 계약의 해제 또는 해지가 가능합니다.

위 사례에서 상담인이 약정 기한까지 소프트웨어 개발을 완성하지 못한 것은 A사의 업무 외적인 일에 대한 요구로 인한 것이므로, 개발 일정 지연에 대하여 상담인에게 귀책사유는 없습니다. 따라서 원사업자인 A사는 「소프트웨어사업 표준하도급 기본계약서」에서 정하고 있는 해제 또는 해지 사유의 해당이 되지 않습니다. 오히려 상담인이 A사의 귀책사유를 이유로 계약의 해지와 민사상 손해배상을 청구할 수 있습니다. 또한, 이러한 A사의 일방적인 계약 해지는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 규정하는 ‘부당한 위탁취소’(제8조)에 해당할 가능성이 높습니다. 하도급법 위반으로 판단될 경우, 시정명령, 과징금, 벌금 등의 제재도 물을 수 있습니다.

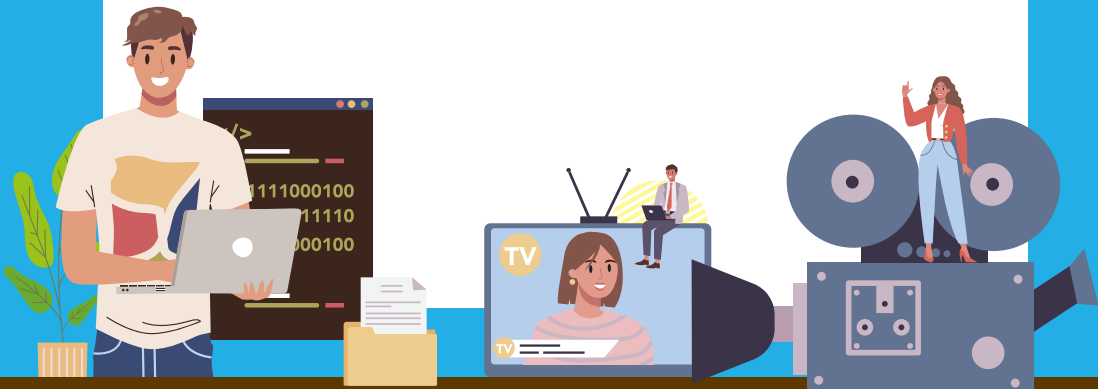


경기도
프리랜서 공정
가이드라인



프리랜서들이 겪는 불공정 거래는 어느 법에 위배되나?

- 주요 규정
- 하도급법 상 불공정행위 금지에 관한 규정



주요규정

● 거래상 지위남용

거래상 지위가 우월한 대기업이 자신의 거래상 지위를 남용하여 열등한 지위에 있는 중소기업의 자유의사를 억압하여 거래하도록 강제하거나 부당한 요구를 하는 경우에 공정거래법상 거래상 지위남용행위(법 제23조 제1항 제4호)에 해당할 수 있습니다. 특히 콘텐츠 유통과정에서 대기업이 자신에 대한 거래의존도가 중소 제작자에 대하여 거래상 우월한 지위를 남용하여 부당하게 불이익을 주는 경우가 자주 발생하곤 합니다. 대금의 지급지연, 부당한 감액요청, 현저히 낮은 대가의 거래요청 등 대금관련 불이익제공행위가 주를 이루며, 기타 기술편취 등 저작권의 침해행위도 거래상 지위남용에 해당됩니다.

● 구속조건부거래

대기업이 자기의 지배 내지 계열을 강화하거나 자기의 경쟁사업자의 힘을 약하게 하는 수단으로서 특정한 상대방 또는 지역에서 거래하거나 하지 않을 것을 조건으로 거래를 하는 경우 그 조건의 구속을 받는 중소기업은 사업활동상 의사결정의 자유가 침해되고, 거래기회가 감소됨으로써 중소기업의 사업활동의 범위를 점차 특정한 대기업에 예측시킬 우려가 있습니다. 이에 따라 공정거래법은 거래상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위를 금지하고 있습니다(법 제23조 제1항 제5호, 유형 및 기준 제7호). 단순히 콘텐츠 공급업자의 영업책임지역이나 거점을 정하는 경우까지 위법한 것으로 보지는 않으나, 엄격한 지역제한이나 고객의 요구에 의한 지역외 판매를 제한하는 행위는 위법한 것으로 볼 수 있습니다.

● 거래강제

대기업은 일반적으로 자신의 요구를 거절하기 어려운 지위에 있는 중소기업에게

원치 않는 거래를 하도록 강요함으로써 중소기업의 자유로운 의사결정을 침해할 우려가 있습니다. 이에 따라 공정거래법은 사업자가 거래상대방으로 하여금 자기 또는 자기가 지정하는 사업자와 거래하도록 강제하는 행위를 금지하고 있습니다 (법 제23조 제1항 제3호, 유형 및 기준 제5호).

거래강제의 가장 전형적인 유형으로서 대기업이 계속적인 거래관계에서 대기업에 종속되고 있는 중소기업 등에 대하여 중소기업이 원하고 있지 않는 상품 또는 서비스를 강제적으로 끼워파는 행위를 들 수 있습니다.

또한 끼워팔기 이외에도 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 조건 등 불이익을 거래상대방에게 제시하여 자기 또는 자기가 지정하는 사업자와 거래하도록 강제하는 행위(유형 및 기준 제5호 다목)도 이에 해당합니다. 예컨대, 중소 하도급업체 또는 부품납품업체에 대해 자기제품 또는 자기가 지정한 제품을 구입하도록 강제하는 경우가 있습니다. 거래상대방은 거래에 불응하는 경우 거래대금의 지연지급, 거래량 감소 및 거래중단 등의 불이익을 가할 경우 위법한 것으로 취급될 것입니다.

● 경쟁사업자 배제

대기업이 시장에서 경쟁관계에 있는 중소기업을 배제하기 위해 중소기업의 사업활동을 현저히 곤란하게 할 우려가 있는 경우에는 부당한 방법을 사용하여 자기 또는 계열회사의 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하는 행위로서 공정거래법에 의해 금지된다(법 제23조 제1항 제2호, 유형 및 기준 제3호). 공정거래법상 경쟁사업자 배제는 가격이라는 경쟁수단을 통한 배제행위에 중점을 두어 ①상품 또는 용역을 정상적인 가격보다 현저히 낮은 가격으로 공급하는 부당염매와 ②높은 가격으로 구입하는 부당고가매입으로 구분됩니다.

● 고객유인

공정거래법은 대기업의 시장진출 자체는 자유경쟁의 견지로부터 제한하고 있지 않으나, 대기업이 그 자본력, 경제력을 이용하여 정상인 상관습에 비추어 부당한 이

익을 가지고 경쟁관계에 있는 중소기업의 고객에 대하여 자기와 거래하도록 유인하는 경우에는 부당한 이익에 의한 고객유인으로서 규제대상에 포섭될 것입니다. 부당한 고객유인의 유형은 경쟁수단을 중심으로 ①부당한 이익제공에 의한 고객유인, ②위계에 의한 고객유인, ③기타 부당한 방법에 의한 고객유인으로 구분하고 있으며 불가피한 사유를 감안하여 규제하고 있습니다. 고객유인의 방법으로 주로 이용되고 있는 경품 및 현상에 관하여는 특수 불공정거래행위로서 경품류고시에서 별도로 규제됩니다.

● 사업활동의 방해

다른 사업자의 사업활동 방해행위는 그동안 대기업의 중소기업에 대한 관계에서 종종 발생해 왔습니다. 예컨대, 대기업은 중소기업이 개발한 콘텐츠를 납품받는 조건으로 또는 도산 등에 대비한다는 명분으로 관련 기술자료를 제출받아 경쟁회사에 넘겨 가격삭감 등에 활용하거나 경쟁 중소기업의 기술을 도용하여 경쟁하기도 하고, 전·후방관계에 있는 중소기업의 콘텐츠를 도용하여 그 시장에 참가함으로써 중소기업의 활동을 방해하는 경우가 이에 해당합니다. 또한 중소기업의 중요한 기술과 기업정보의 유출 또는 거래고객을 탈취하기 위한 수단으로서 인력을 유인·채용하거나 인력을 대량 스카우트함으로써 중소기업의 사업활동을 곤란할 정도에 이르게 하는 경우도 금지대상이 될 것입니다.(법 제23조 제1항 제5호 후단, 유형 및 기준 제8호) 시장지배적사업자가 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 경우에는 별도로 시장지배적사업자의 지위남용행위로서 규제됩니다(법 제3조의2 제1항 제3호).

● 사업자단체를 통한 불공정거래행위

사업자단체가 대기업을 중심으로 활동하고, 중소기업에 대하여 제명, 활동제한 그 밖의 불이익 취급을 하는 것은 사업자단체에 의한 중소기업의 기능 활동의 제한으로서 공정거래법 제26조 제1항 제3호에 위반할 수 있습니다.

하도급법상 불공정거래행위 금지의 근거

하도급거래의 비중이 지속적으로 증가해 오고 있음에도, 주로 대기업인 원사업자와 중소기업인 수급사업자 간의 호혜적 관계가 정립되지 못한 채 원사업자(대기업)는 계약체결시 월등한 협상력을 바탕으로 수급사업자(중소기업)에게 일방적으로 불리한 각종 부당한 거래조건을 설정하는 등 거래상지위의 남용행위가 빈번히 발생하고 있습니다.

하도급 거래관계에서 발생하는 원사업자와 수급사업자 간의 힘의 불균형에 따른 지위남용행위에 대해 공정거래법상의 규정만으로는 규제가 불충분합니다. 이에 따라 실거래에 만연한 불공정한 하도급 거래관행을 효과적으로 규제하기 위해 하도급법을 제정하여 시행하고 있습니다.

〈하도급법상 원사업자의 주된 의무사항〉

의무사항	개요
서면의 교부 (제3조)	원사업자는 발주시에 수급사업자의 급부내용, 하도급대금, 지불기일 및 지불방법 등을 기재한 서면을 수급사업자에게 교부할 의무가 있음
서류의 작성·보존 (제3조)	원사업자는 수급사업자에 대해 제조위탁, 건설위탁, 수리위탁, 용역위탁을 한 경우는 급부의 내용, 하도급대금 등을 기재한 서류를 작성하여 3년간 보존할 의무가 있음
하도급대금 지급 (제13조)	원사업자는 수급사업자와의 합의하에 하도급대금 지급기일에 대해 물품 등을 수령한 날로부터 기산하여 60일 내에 가능한 한 짧은 기간으로 정할 의무가 있음

지연이자 지불 (제13조)	원사업자는 하도급대금을 지급일까지 지불하지 않은 경우에는 수급 사업자에 대해 물품 등을 수령한 날로부터 기산하여 60일을 경과한 날부터 실제 지불한 날까지의 기간에 대해 이 일수에 따라 당해 미지불액에 20%를 곱한 액의 지연이자를 지불할 의무가 있음
-------------------	--

〈하도급법상 원사업자의 주된 금지사항〉

금지사항	개요
부당한 하도급대금 결정 금지 (제4조)	동종 또는 유사품의 가격 또는 시중가격에 비해 현저하게 낮은 하도급대금을 부당하게 결정하는 것
수령거부 등 금지 (제8조)	주문한 상품 등의 수령을 거부하는 것
부당한 반품금지 (제10조)	수취한 물품 등을 반품하는 것
하도급대금의 감액금지 (제11조)	사전에 정한 하도급대금을 감액하는 것
하도급대금지불 지연금지 (제13조 제1항)	하도급대금을 목적물수령일로부터 60일 이내에 정한 지불기일까지 지불하지 않는 것
할인 곤란한 어음교부의 금지 (제13조 6항)	일반 금융기관에서 할인받는 것이 곤란한 것으로 인정되는 어음을 교부하는 것

물품구매대금 등의 부당결제청구 금지 (제12조)	원사업자가 지정한 물품, 용역을 강제적으로 구입, 이용시키는 것
부당한 경제상의 이익의제공요청 금지 (제12조의2)	수급사업자로부터 금전, 노무의 제공 등을 강요하는 것
기술자료 제공금지 (제12조의3) (2010.7.26 시행)	정당한 사유 없이 수급사업자의 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 강요하는 것 자기 또는 제3자를 위하여 유용하는 것
부당한 급부내용의 변경 및 부당한 재작업의 금지 (제16조)	비용을 부담하지 않고 주문내용을 변경하거나 또는 수령 후에 재 작업을 시키는 것
보복조치의 금지 (제19조)	수급사업자가 원사업자의 불공정한 거래행위를 공정거래위원회에 알린 것을 이유로 하여 수급사업자에 대해 수량삭감, 거래정지 등의 불이익을 주는 것
유상지급원자재 등의 대가의 조기결제 금지 (제12조)	유상으로 지급한 원자재의 대가를 당해 원자재를 이용한 급부에 관계한 하도급대금지불기일보다 이른 시기에 상계하거나 지급하게 하는 것

• 부록1 •

프리랜서 콘텐츠 분야 불공정 사례



영화, 비디오, 애니메이션 분야

국내영화산업에서는 영화제작사와 창업투자사, 배급사 등의 수직구조 하에 투자 및 배급사의 영향력 및 거래상 지위가 지속적으로 강화되어 왔는데, 이 과정에서 상영업자나 배급사가 영화제작사나 상영관 등에 대해 불공정거래 관행 특히, 투자금에 대한 이자 및 지분의 불균형적 배분을 하는 일들이 발생하곤 합니다.

실제 사례 • 영화상영업자가 영화배급업자와의 거래관계에서 사전 협의나 통보 없이 일방적인 영화조기 종영하거나, 일방적으로 계약상 부율(수익분배비율)을 변경하거나, 상영관 이익을 목적으로 하여 마케팅 수단의 하나로 활용되는 무료초대권을 배급업자와 사전협의 없이 대량으로 발급하는 행위 등이 불공정한 것으로 판명된 사례가 있음

실제 사례 • 영화배급업자가 기업경영상의 이유나 혹은 거래상대방의 귀책사유 없이 약 2년의 기간 동안 특정 지역의 영화상영업자들 중 특정 영화상영업자에 대하여만 영화배급을 거절한 경우나, 영화배급업자가 자신이 판권을 소유한 영화를 대상으로 케이블TV 방영권을 공급하면서 정당한 이유 없이 자기의 계열회사에게만 독점적으로 공급하고, 경쟁사업자이자 비계열 회사인 영화방송채널사업자에게는 케이블TV 방영권을 공급하지 않는 경우 등이 문제된 예가 있음



음악, 공연 분야

음악산업은 작곡가, 작사가 등 음반제작자, 연주자, 가수, 프로듀서, 음원콘텐츠공급자, 음반제작사, 방송사나 연예기획사, 인터넷포털 등 다양한 주체와 총위로 구성됩니다. 그 중에서 개인제작자, 가수 및 연주자들이 대규모 음악 유통업자와의 사이에서 불공정 계약을 체결할 위험에 노출되기도 합니다.

음악 및 공연산업에서 주로 문제되는 행위로는 연주자와 관련하여 연주료의 미지급, 연주대상곡명 및 곡수의 미고지, 음원 등 디지털콘텐츠 판매 관련 수익배분, 수익배분시 정산자료에 관한 해석, 재녹음 및 추가작업 등과 관련한 불공정 계약이나, 프로듀싱계약 과정에서 음악감독료의 미지급 내지 지급지연, 인도지연 등 계약이행지체, 표절 등 제3자와의 저작권 분쟁시 책임부담, 뮤직비디오나 무단 편곡 등으로 감독의 저작권 내지 인격권을 침해하는 행위들입니다.

실제 사례 • 방송프로그램제작 및 음반제작업을 영위하는 사업자가 연예인과 연예 활동에 관한 전속계약을 체결하면서 계약기간을 ‘첫 번째 음반 발매 후 5년째 되는 날’ ‘내지’ 조연급이상의 배역출연으로 첫 번째 작품의 데뷔일로부터 5년째 되는 날’ 등으로 정하고, 계약기간 위약시 손해배상액을 향후 예상이익에 비추어 과다하게 설정한 경우가 문제되었음. 이는 계약만료 후 당해 연예인의 활동기회를 제한할 수 있어 불리한 거래조건을 일방적으로 설정한 행위에 해당하며, 아울러 계약상 손해 배상액에 관한 규정이 동종업계의 거래내용과 비교하여 지나치게 과다할 경우에도 불공정한 것으로 볼 수 있음



방송 분야

국내 방송산업이 다매체 다채널시대에 접어들면서 방송프로그램이 종전의 자체제작 방식에서 외주제작방식으로 전환되고 있고, 산업인력 구조도 정규직 스태프(근로계약) 중심에서 프로젝트별 프리랜서 중심(도급계약)으로 바뀌어 감에 따라 불공정한 내용의 계

약이 체결되는 일들이 발생하곤 합니다.

방송사와 외주 제작사들간에는 프로그램 제작비 산정상의 부적절성, 방송사에 의한 제작시설 및 인력사용의 강제 및 부당한 요금부과, 추가제작비 발생시 부담의 전가, 프로그램에 대한 저작권 문제, 협찬 및 간접광고, 지체상금 부과, 계약의 해지 및 해제 등이 문제될 수 있습니다.

방송사와 방송극작가 사이에는 원고료의 지급지연 및 미지급, 방송 횟수를 늘려서 추가 제작할 경우 적정 원고료의 책정을 거부하거나 방송프로그램의 2차적 사용(DVD제작, 해외판권)시 수익배분의 문제, 혹은 프로그램의 경연출품시 수상주체, 작가변경에 다른 원고료지급 문제, 방송프로그램의 방송시간 및 횟수변경, 방송중단 내지 폐지시의 급여, 원고인도 지연에 따른 지체상금 등과 관련한 불공정 계약들이 문제됩니다.

또한 방송사와 방송스텝 사이에는 스텝에 대한 급여의 지급지연, 하도급시 업체직원의 인건비 미지급, 안전배려의무 미준수로 인한 사고발생시 책임부담, 보험가입부담 주체, 업무수행으로 인한 진행비, 경비 등의 증빙 미지급, 계약의 일방적 해제 및 해지 등과 관련된 불공정 계약들이 체결되기도 합니다.

실제 법위반 사례에서는 종합유선방송사업자(SO)가 자주 연루되고 있습니다.

실제 사례 ● 종합유선방송사업자(SO)가 방송채널사용사업자(PP)와 신규 프로그램 공급계약(소위 런칭계약)을 체결하면서 런칭에 따른 프로그램 사용료 지급은 무료로 하고, 신규채널 런칭에 따른 광고비 명목의 금원을 지급받았음. 일반적으로 프로그램을 공급받은 경우 프로그램 사용료를 지불해야 하는데 이를 무료로 하고, 자신이 부담해야 할 홍보비용을 거래상대방에게 전가하여 광고비 명목으로 ‘런칭비’를 징수하는 것은 자신의 거래상 지위를 이용하여 상대방의 자유로운 의사결정을 억압하고 불이익을 제공한 불공정한 거래행위에 해당함

실제 사례 ● 종합유선방송사업자(SO)가 자신의 거래상 지위를 이용하여 방송채널 사용사업자(PP)에게 자신이 발행하는 잡지의 광고지면을 구입하도록 강요하는 것은 PP에게 불필요한 비용을 발생시키고, 자신의 요구를 거절하기 어려운 거래상대방에게 원치 않는 상품을 부당하게 구입하도록 강제하는 것으로서 불공정한 거래행위에 해당함



온라인 게임 분야

온라인 게임산업은 유독 영세한 제작사와 상당규모와 자본력을 갖춘 퍼블리셔간에 지위의 격차가 커서 불공정한 거래가 발생할 소지가 큰 분야라고 할 수 있습니다. 특히 온라인 게임이 개발되기까지는 집중적인 연구와 투자가 요구되므로 제작사의 입장에서 수익 창출 시점이 되기 전에 자금난 등을 겪는 경우가 많은데, 이 점을 악용하여 계약서를 교부하지 않거나 기술에 관련된 불공정 계약이 체결되거나, 대금지급조건, 저작권 귀속 등과 관련하여 상대방에게 불이익을 강요하는 일들이 많이 발생하고 있습니다.

실제 사례 ● 게임업체가 수급사업자에게 온라인게임 그래픽 제작 및 캐릭터 상품제작 등 총 116건의 용역 및 제조를 위탁하였는데, 하도급계약에 관한 서면을 용역수행이 시작된 후 짧게는 11일에서 최장 587일이 지나서야 발급하다가 적발되었음. 계약서미교부는 대표적인 불공정행위로 볼 수 있고, 이에 하도급법 제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)에서는 위탁자로 하여금 용역수행행위를 시작하기 전까지 수탁자에게 서면을 교부하도록 규정하고 이를 위반한 경우에는 하도급대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌금이 부과될 수 있음. 이에 따라 해당업체는 하도급법 제3조 위반을 이유로 공정거래위원회에 의해 11,000,000원의 과징금을 부과받았음

실제 사례 ● 온라인게임 개발업을 영위하는 사업자가 온라인 게임 등을 PC방에 판매하면서 PC방 요금 과금방식에 있어서 기존의 개별 정량제를 없애고, 이전제품과 새로 출시된 온라인 게임을 이용할 수 있는 통합정량제 상품을 출시하였음. 반면 양 제품을 별도로 구매할 수 있는 개별정량제는 두고 있지 않았음. 이러한 행위는 전형적인 끼워팔기식 거래로서 인기게임을 구매하기 위해서는 구매를 원치 않는 비인기제품 혹은 신규제품을 사실상 구입하도록 강제하는 행위에 해당하므로 불공정거래행위로 제재를 받게 됨

실제 사례 ● 게임업체가 자신이 운영하는 게임포털 사이트에서 판매되는 아바타 캐릭터, 배경, 악세서리 등의 제작을 용역위탁하면서 이에 대한 하도급대금을 지급기한 보다 3개월 정도 초과하여 지급하면서도 이에 대한 지연이자 지급하지 않은

점이 문제되었음. 이에 대해 공정거래위원회는 하도급법 제13조(하도급대금의 지급 등) 위반을 인정하면서 자연이자를 지급할 것을 명령하였음

실제 사례 ● 게임퍼블리셔가 개발업체와 ‘온라인게임 콘텐츠 제공 및 사용계약’을 체결하면서 게임콘텐츠에 대한 서버플랫폼 개발 및 유지보수사업을 지속할 수 없을 경우에는 게임의 전 소스코드 및 운영매뉴얼 일체를 무상양도토록 한 점이 문제되었음. 이런 계약조항은 공정거래법상 거래상 지위남용행위에 해당할 수 있고, 「콘텐츠산업진흥법」에서 금지하는 불공정계약에 해당될 수도 있음. 이에 따라 해당 업체는 공정거래위원회에 의해 위반행위금지명령 및 계약서 조항 삭제·수정 명령을 부과 받았음



인터넷 포털 등 지식정보 분야

포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업, 뉴스제공업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 등 지식정보 서비스업은 콘텐츠산업 가운데도 향후 발전속도가 클 것으로 전망되는 분야이지만 동시에 주로 인터넷 포털 등을 중심으로 불공정 거래관행 등이 포착되기도 합니다. 인터넷 포털의 경우 콘텐츠공급자와 이용자의 중간적 위치에서 이용자의 트래픽수를 기반으로 광고수익을 올리는 한편, 이를 위해 각종 콘텐츠제작자들에게 불이익을 제공하는 방식의 불공정거래행위가 종종 문제되고 있습니다.

최근 들어서는 글로벌 포털의 영향력이 막강해지면서 플랫폼을 이용하는 국내 업체에 대한 거래상 지위나 독과점적 지위의 남용행위가 발생하고 있고 이에 대해 국내법을 적용하여 규제하는 경향이 강하게 나타나고 있으므로 업계의 각별한 주의가 요구되고 있습니다.

실제 사례 ● 무선인터넷망을 보유한 이동통신사업자가 자신으로부터 무선인터넷 인프라를 빌려 쓰는 망개방 사업자와 “무선인터넷상호접속에 관한 협정서”를 체결

하였고, 그에 따라 이후 “무선인터넷망 상호접속 관련 정보이용료의 청구 및 수납 대행 부속합의서”를 체결하였음. 이에 의거하여 망개방 사업자가 무선인터넷 서비스를 개시하였으나, 이동통신사업자가 계약서상 어떠한 합의도 없이 자사 이동통신 서비스 가입자 중 특정요금제 가입자에 대하여 망개방 사업자로부터의 콘텐츠 구매를 원천적으로 차단하였음. 이 같은 행위는 관련시장에서의 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 행위로 인정되었음

실제 사례 • 인터넷포털이 UCC 동영상 공급업체와 동영상 콘텐츠 목록자료(색인 데이터베이스)를 제공받는 계약을 체결하면서, 자사 포털의 검색결과로 보여지는 동영상 정보서비스에 자신과 협의 없이 광고를 게재할 수 없다는 거래조건(동영상 상영 전 광고 금지)을 설정한 점이 문제되었음

실제 사례 • 인터넷 사이트를 운영하는 국내 사업자가 미국 소재의 글로벌 포털업체와 애드센스이용계약을 체결하였는데, 부정클릭을 이유로 해당 업체로부터 계약 해지를 당한 점이 문제되었음. 이에 대해 공정거래위원회는 해당 미국 포털업체의 약관이 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당하여 한국의 약관규제법에 위반으로 판단하고, 이를 수정·삭제하도록 시정명령을 부과하였음



출판 분야

출판물의 유통구조는 최근 들어 off-line의 중소서점의 비중이 빠르게 감소하는 반면 대형서점, 대형마트 및 on-line 판매방식으로의 전환이 활발해지면서, 출판물제작업자들의 교섭력과 거래상 지위의 불균형이 심화되고 있습니다. 이에 따라 불공정한 거래관행도 종전보다 노골화되고 있는데, 출판산업의 특성상 주로 거래상 우월적 지위를 점한 서점들이 가격인하의 부담을 출판업체에 전가하는 방식 등으로 불공정한 거래가 일어나게 됩니다.

실제 사례 ● 반값할인과 같은 이벤트 행사를 진행하면서 출판사로 하여금 간행물과 학습지의 가격인하를 요청하는 관행이 문제되었음. 도서가격을 중심으로 경쟁구도는 표면적으로 가격경쟁과 소비자권익을 촉진시키는 것으로 보이지만, 경쟁과정에서 발생하는 부담을 전적으로 출판업계에 지우는 것은 불공정한 거래에 해당할 수 있음



광고 분야

광고는 대개 광고주가 광고회사에 광고제작을 의뢰해서 기획안을 확정하면, 광고회사가 이를 다시 광고제작회사에 재의뢰하는 하도급 구조를 통해 이루어지는데, 이 과정에서 법에서 정하는 계약서 교부의무를 이행하지 않거나, 대금을 현저히 낮게 책정하는 행위들이 적발되고 있습니다.

제조위탁 혹은 용역위탁에 있어 원사업자는 제조위탁을 할 때 또는 용역을 위탁을 할 때 수급사업자에게 계약서 등의 서면을 교부하여야 하는 것이 원칙이지만, 늦어도 수급사업자가 작업에 착수하기 전 혹은 용역수행행위를 시작하기 전까지는 이를 교부해야 하며, 당초의 계약내용이 변경될 경우에는 특단의 사정이 없는 한 반드시 추가·변경서면을 작성·교부해야 합니다.

실제 사례 ● 대형 광고회사가 수급사업자(광고물 등을 제작하는 중소기업자)에게 홍보영화 제작 등의 용역을 위탁하면서 정당한 사유 없이 용역 업무 수행 중 혹은 용역 업무 완료 직후에 계약서를 교부한 행위. 계약서와 같은 서면교부 지연행위는 정당한 사유가 있는 때, 즉 지연교부를 인정할 만한 급박한 사정이 있거나 회복할 수 없는 손해가 있는 경우에는 정당화될 수 있으나, 지연교부 행위에 대해 합리적인 사유가 존재하지 않고, 단순히 실무자의 실수로 인한 지연교부인 경우에는 정당한 사유로 인정되지 않음

실제 사례 • 용역위탁 시 서면교부지연행위, 부당한 방법을 이용하여 통상 지급되는 대가보다 현저하게 낮은 수준으로 하도급대금을 결정하는 행위 내지 일방적으로 낮은 단가로 하도급대금을 결정하는 행위 및 광고방영이 되지 않았다는 이유로 제작 실비를 지급하지 않거나 견적금액의 50% 수준에서 하도급대금을 결정하는 행위 등 부당한 하도급대금 결정행위 등이 불공정한 하도급 거래로 판명되었음



웹툰 분야

웹툰 분야는 최근 들어 시장이 급속도로 팽창하는 대표적 콘텐츠 분야이자, 지식산업으로서 진입장벽이 낮아서 프리랜서들이 급증하는 분야입니다. 이에 따라 콘텐츠 분야에서 발생하는 불공정한 계약 형태들이 나타나고 있고, 이에 더하여 웹툰에 특유한 저작권 관련 불공정 행위들도 목격되고 있어서 주의를 요하고 있습니다.

최근들어서는 웹툰서비스 사업자가 웹툰을 원천으로 타 장르를 재생산하는 경우 2차적 저작물 사용권을 원저작자가 소유해야 함에도 불구하고 이들의 지식재산권을 제한하는 경우들이 문제되고 있습니다. 이런 행위들은 「약관규제법」 제11조(고객의 권익 보호)이나 「만화진흥에 관한 법률(이하 '만화진흥법'이라 함)」 제9조(유통질서의 확립) 제1항에 위반될 가능성이 큽니다.

실제 사례 • 웹툰 서비스 사업자(21개사)가 웹툰 작가들과 웹툰 콘텐츠 연재 계약을 체결하면서, 계약 내용에 2차적 저작물 사용권을 포함한 권리까지 설정한 것이 문제되었음. 웹툰이 드라마, 영화화 되어 OSMU가 활발한 상황에서 웹툰 창작에 대한 기여도가 가장 큰 웹툰작가의 저작재산권 행사를 부당하게 제한하고 웹툰서비스사업자의 폭리를 가능하게 하는 조항으로서 볼 수 있음. 이에 따라 공정거래위원회는 해당 약관조항은 제3자와 계약을 체결할 권리를 부당하게 제한하는 조항에 해당되어 약관규제법 제11조에 따라 무효라고 판단하였음

• 부록2 •

거래 시 유의사항(체크리스트)



대금관련 유의사항

● 현저하게 낮은 대가로의 거래 요청

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 수탁자가 용역 위탁 거래 시 새롭게 설비 투자와 인력을 준비 할 필요가 있는 등으로 해당 용역의 제공에 필요한 비용 등도 크게 증가하여 수탁자가 대가 인상을 요구하였음에도 불구하고 관련 비용 증가를 충분히 고려하지 않고 현저히 낮은 대가를 정하는 경우
- ② 수탁자에게 단기의 납기를 설정함으로써 해당 용역의 제공에 필요한 비용 등도 대폭 증가하게 되어 수탁자가 대가의 인상을 요구하였음에도 불구하고 소요되는 비용증가에 대한 충분한 고려없이 현저하게 낮은 대가를 정하는 경우
- ③ 다량 내지 장기간의 역무의 위탁거래를 하는 것을 전제로 수탁자에게 견적을 시켜, 그 견적에 있어서의 대가를 소량 내지 단기간 밖에 거래하지 않는 경우의 대가로 하여 정하는 경우
- ④ 특정 수탁자에 대해 합리적인 이유가 없음에도 불구하고 다른 수탁자의 대가에 비해 차별적으로 낮은 대가를 정하는 경우

〈법에 위반되지 않는 경우〉

- ① 위탁자가 요청하는 대가가 수탁자의 견적상의 대가에 비해 현저히 낮고, 수탁자입

장에서 위탁자에 의한 부당한 대금결정행위로 인식된다고 하더라도 위탁자의 요청 대가로 수탁하려고 하는 다른 사업자가 존재하는 경우 등 그것이 대가에 관한 협상의 일환으로 행하여지는 것이며 대가가 수급관계를 반영한 것으로 인정되는 경우에는 거래상 지위의 남용이 문제되지 아니한다.

- ② 또한 현저하게 낮은 대가로 용역의 위탁 거래를 요청하는 것이 우월적 지위 남용 행위에 해당하는지 여부는 대가 결정시 수탁자와 충분한 협의가 이루어졌는지 여부 등 대가 결정 방법, 다른 수탁자의 대가에 비해 차별적인가 여부 등 결정 내용, 거래의 대상이 되는 용역의 수급 관계를 반영하고 있는지 여부 등 대가의 결정 상황 등을 감안하여 종합적으로 판단하게 된다.

● 대금의 감액요청

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 수탁자에게 책임이 없음에도 불구하고 용역의 제공을 받은 후에 예산 부족 등 위탁자 측의 일방적인 사정에 의해 계약에서 정한 대금을 감액하는 경우
- ② 제공받은 용역에 대해 사전에 정해진 검사 기준을 자의적으로 엄격하게 적용하여 위탁 내용과 다르다는 것과 결함이 있다는 것 등을 이유로 계약에서 정한 대금을 감액하는 경우
- ③ 위탁자 측의 일방적인 사정에 의해 거래의 대상이 되는 용역의 사양 등의 변경, 재작업 또는 추가적인 용역의 제공을 요청한 결과, 수탁자의 작업량이 크게 증가하였기 때문에 수탁자에 대하여 해당 작업량 증가분과 관련된 대금의 지급을 인정하였음에도 불구하고 당초 계약에서 정한 대금 밖에 지급하지 않는 경우
- ④ 수탁자가 위탁자의 요청에 따라 설비 투자와 인원을 준비하는 등 위탁자에 대한 용역 제공의 준비를 위한 비용을 부담하지 않을 수 없었음에도 불구하고 위탁자 측의 일방적인 사정에 따라 해당 용역의 일부 위탁을 취소하고, 계약에서 정한 대금에서 위탁 거래 감소분에 관련된 대금을 감액하는 경우

〈법에 위반되지 않는 경우〉

- ① 위탁자가 요청하는 대가가 수탁자의 견적상의 대가에 비해 현저히 낮고, 수탁자입장에서 위탁자에 의한 부당한 대금결정행위로 인식된다고 하더라도 위탁자의 요청 대가로 수탁하려고 하는 다른 사업자가 존재하는 경우 등 그것이 대가에 관한 협의의 일환으로 행하여지는 것이며 대가가 수급관계를 반영한 것으로 인정되는 경우에는 거래상 지위의 남용이 문제 되지 아니한다.
- ② 또한 현저하게 낮은 대가로 용역의 위탁 거래를 요청하는 것이 우월적 지위 남용 행위에 해당하는지 여부는 대가 결정시 수탁자와 충분한 협의가 이루어졌는지 여부 등 대가 결정 방법, 다른 수탁자의 대가에 비해 차별적인가 여부 등 결정 내용, 거래의 대상이 되는 용역의 수급 관계를 반영하고 있는지 여부 등 대가의 결정 상황 등을 감안하여 종합적으로 판단하게 된다.

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 위탁할 때 하도급대금을 감액할 조건 등을 명시하지 아니하고 위탁 후, 협조요청 또는 거래상대방으로부터의 발주 취소·경제상황의 변동 등 불합리한 이유를 들어 감액하는 행위
- ② 수급사업자와 단가인하에 관한 합의가 성립한 경우, 당해 합의 성립 전에 위탁한 부분에 대하여도 일방적으로 이를 소급 적용하는 방법으로 하도급대금을 감액하는 행위
- ③ 하도급대금을 현금으로 또는 지급기일전에 지급함을 이유로 과다하게 감액하는 행위
- ④ 원사업자에 대한 손해발생에 실질적 영향을 미치지 아니하는 경미한 수급사업자의 과오를 이유로 일방적으로 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑤ 원사업자가 사실상 무리한 납기를 정해 놓고 납기 내에 납품하지 못함을 이유로 감액하는 행위
- ⑥ 계속적 발주를 이유로 이미 확정된 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑦ 당초 계약내용과 달리 간접노무비, 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등을 감액하는 행위

- ⑧ 목적물을 저가로 수주하였다는 등의 이유로 당초계약과 달리 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑥ 계속적 발주를 이유로 이미 확정된 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑦ 당초 계약내용과 달리 간접노무비, 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등을 감액하는 행위
- ⑧ 목적물을 저가로 수주하였다는 등의 이유로 당초계약과 달리 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑨ 위탁내용 및 조건에는 변함이 없음에도 계약내용을 변경하는 등의 방법을 이용하여 결과적으로 하도급대금을 감액하는 행위
- ⑩ 고용보험법, 산업안전보건법 등 법령에 의해 원사업자가 일정 부분을 부담하도록 되어 있는 고용보험료, 표준안전관리비 등을 수급사업자에게 전가시키는 행위
- ⑪ 하도급계약 후 추가시공이 있었음에도 불구하고 동 추가 하도급대금이 경미함을 이유로 이를 감액하여 당초의 계약금액만을 지급하는 행위

● 대금의 지급 지연

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 회사의 지급절차의 지연 등을 이유로 하여 위탁자 측의 일방적인 사정에 의해 계약에서 정한 만기일에 대금을 지급하지 않는 경우
- ② 용역의 성과물을 대상으로 하는 거래에서 용역의 성과물의 제공이 끝났음에도 불구하고 해당 성과물의 검수를 자의적으로 지연시킴으로써 계약에서 정한 만기일에 대금을 지급하지 않는 경우
- ③ 용역의 성과물을 대상으로 하는 거래에서 대금은 해당 성과물을 위탁자가 실제로 사용한 후에 지급하기로 되어있는 경우 위탁자 측의 일방적인 사정에 의해 해당 성과물의 사용시기를 당초 예정보다 크게 지연시키고, 이를 이유로 대금 지급을 지연하였을 경우

〈법에 위반되지 않는 경우〉

만기일이 길게 설정되는 경우라고 해도 대금에 대해 만기일까지 수탁자측의 자금 조달 비용을 감당한 대가로 협상을 하는 등 부당하게 불이익을 수탁자에게 주지 않은 것으로 인정되는 경우에는 거래상 지위 남용에 해당되지 않는다.



목적물 관련 불공정거래

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 위탁자 측의 일방적인 사정에 의해 거래 대상이 되는 용역의 사양 등을 변경하였음에도 불구하고 사양에 부합하지 않는다는 이유로 수탁자에게 재작업을 시키는 경우
- ② 용역을 제공받는 과정에서 용역의 내용을 승인했음에도 불구하고 제공을 받은 후에 수탁자에게 재작업을 시키는 경우
- ③ 제공받은 용역에 대해 사전에 정해진 검사 기준을 자의적으로 엄격히 적용하여 위탁 내용과 다르다거나 결함이 있다는 것 등을 이유로 수탁자에게 재작업을 시키는 경우
- ④ 수탁자가 위탁자에게 사양 내지 검사 기준의 명확화를 요구 했음에도 불구하고 명확히 하지 않은 채, 사양 등과 다르다거나 결함이 있다는 것 등을 이유로 수탁자에게 재작업 시키는 경우

〈법에 위반되지 않는 경우〉

- ① 제공받은 용역의 내용이 위탁시점에 결정된 조건에 부합되지 않는 경우에는 위탁자가 재작업을 요청하는 것은 문제가 되지 않는다.
- ② 또한 재작업을 위해 통상 필요한 비용을 위탁자가 부담하는 등 수탁자에게 불이익을 주지 않는다고 인정되는 경우에는 우월적 지위 남용의 문제가 되지 않는다.

㉠ 발주의 취소 또는 제작물의 수령거부

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 위탁내용이 불명확하여 수급사업자가 납품·시공한 목적물의 내용이 위탁내용과 상이한지 판단이 곤란함에도 불구하고 수령을 거부하는 행위
- ② 검사기준을 정하지 아니하고 통상의 기준보다 높은 기준을 적용하거나, 검사기준을 정하였다고 하더라도 내용이 불분명하거나 당초계약에서 정한 검사기준보다 높은 기준을 적용하여 수령을 거부하는 행위
- ③ 위탁시 납기를 정하지 아니하거나 납기를 변경할 경우 이를 명확히 하지 아니하고 납기지연을 이유로 수령을 거부하는 행위
- ④ 원사업자가 발주자·외국수입업자·고객의 클레임, 판매부진 등을 이유로 이미 위탁한 물품의 수령을 거부하는 행위
- ⑤ 원사업자가 수급사업자의 부도 등에 따라 안정적인 공급이 어렵다고 판단해서 이미 발주한 물품의 수령을 임의로 거부하는 행위
- ⑥ 원사업자가 여러 품목을 위탁하고 일부 품목의 불량률 이유로 다른 품목에 대하여도 수령을 거부하는 행위
- ⑦ 발주자의 발주취소 또는 발주중단 등의 이유로 이미 위탁한 목적물의 수령을 거부하는 행위

〈법에 위반되지 않는 경우〉

- ① 발주내용과 다른 물품을 납품하거나 납기를 어겨 납품하는 경우 수령의무가 없다.
- ② 수급사업자의 부도, 제3자에 의한 강제집행, 파산선고 신청 등 수급사업자의 경영상 중대한 사유가 발생하여 계약내용을 이행할 수 없다고 인정되는 경우 발주 취소 혹은 변경이 가능하다.
- ③ 수급사업자가 원사업자의 승인 없이 영업의 양도를 결의하거나 타 회사로 합병될 경우 발주 취소 혹은 변경이 가능하다.

- ④ 수급사업자가 특별한 사유 없이 착수를 상당동안 지연하는 등으로 기간 내에 제조 및 건설이 곤란할 경우 발주 취소 혹은 변경이 가능하다.

● 부당반품의 금지

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 거래상대방으로부터의 발주 취소 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 목적물을 반품하는 행위
- ② 검사기준 및 방법을 불명확하게 정함으로써 목적물을 부당하게 불합격으로 판정하여 이를 반품하는 행위
- ③ 원사업자가 이미 수령한 물품을 발주자·외국수입업자 고객의 클레임, 판매부진 등을 이유로 반품하는 행위
- ④ 원사업자가 수급사업자 이외의 제3자에게 검사를 위탁한 경우로서 수급사업자가 제3자의 검사를 필하여 납품하였음에도 이를 반품하는 행위
- ⑤ 수급사업자의 납기지연이 있었으나, 이를 용인한 객관적 사실이 있었음에도 이를 수령한 후 납기지연을 이유로 반품하는 행위



거래상대방 관련 불공정거래

● 거래상대방 사업자에 대한 상품 등의 구입요청

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 위탁 거래 담당자 등의 용역의 위탁 거래에 영향을 미칠 수 있는 자가 구매를 요청하는 경우
- ② 수탁자에 대해 체계적으로 또는 계획적으로 구매를 요청하는 경우

- ③ 구입 의사가 없다는 표명이 있는 경우 또는 그 표명이 없어도 명백하게 구매할 의사가 없는 것으로 인정되는 경우에 재차 구매를 요청하거나 불필요한 상품을 일방적으로 송부하는 경우

● 거래상대방 사업자에 대한 협찬금 등의 요청

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 협찬금 등의 부담 금액 및 산출 근거, 용도 등에 대하여 위탁자와 수탁자 간에 명확하게 합의되어 있지 않은 경우로서 수탁자에게 사전에 예측할 수 없는 불이익을 주게 되는 경우
- ② 다음과 같은 방법으로 협찬금 등을 부담시키고 수탁자에게 불이익을 주게 되는 경우
 - 위탁자의 결산대책 등 손익이 악화된 것을 이유로 협찬금 등의 부담을 요청하는 경우
 - 상품납품 업체 등 다른 사업자에 대해서도 협찬금 등의 부담을 요청하고 있다는 것을 이유로 수탁자가 받는 직접적인 이익의 범위를 넘어 협찬금 등의 부담을 요청할 경우
 - 일정한 기간에 일정한 정도 이상의 위탁 거래를 한 경우 협찬금 등을 징수하는 것을 사전에 정하고 있었던 경우에 해당 거래량에 이르지 않았음에도 불구하고 해당 협찬금 등의 부담을 요청할 때

〈법에 위반되지 않는 경우〉

유통업자가 상품납품업체에 협찬금 등의 부담을 요청하는 경우에는 해당 비용을 부담하는 것이 납품상품의 판매 촉진으로 이어져 수탁자에게도 직접적인 이익이 될 수 있으며, 따라서 이런 경우에는 법위반이 되지 않는다.



기술 관련 불공정거래

● 콘텐츠에 관한 권리 등의 일방적 취급

〈법에 위반되는 경우〉

(콘텐츠의 권리 양도)

- ① 수탁자에게 권리가 발생하였음에도 불구하고 해당 콘텐츠가 위탁자와의 위탁 거래 과정에서 얻어진 것 또는 위탁자의 비용 부담으로 작성되어졌다는 것을 이유로 일방적으로 해당 콘텐츠에 관한 저작권, 특허권 등의 권리를 위탁자에게 양도시키는 경우
- ② 수탁자에게 권리가 발생하는 경우에 2차 이용에 따른 수익 배분을 조건으로 하여 저작권 등의 권리를 위탁자에게 양도하였음에도 불구하고 2차 이용 관리를 하는 위탁자가 수탁자로부터 2차 이용의 요청·제안에 대해 합리적인 이유 없이 응하지 않을 경우

(정보성산물 2차 이용 제한 등)

- ① 수탁자에게 권리가 발생하고 위탁자는 권리가 발생하지 않음에도 불구하고 위탁자가 자신에게도 권리가 발생한다고 주장하고 이를 전제로 수탁자와 일방적으로 해당 콘텐츠의 2차 사용 수익 배분 등의 거래 조건을 결정할 경우 또는 2차 이용을 제한하는 경우
- ② 수탁자에게 권리가 발생하는 경우에 위탁자가 해당 콘텐츠가 위탁자와의 위탁 거래 과정에서 얻어진 것 또는 위탁자의 비용 부담으로 작성되어진 것을 이유로 수탁자 대해 일방적으로 해당 콘텐츠의 2차 사용 수익 배분 등의 거래 조건을 결정할 경우 또는 2차 이용을 제한하는 경우
- ③ 수탁자에게 권리가 발생하는 경우에 수탁자가 위탁자가 제시하는 콘텐츠 제작의 대가 이외에 해당 콘텐츠의 2차 이용에 따른 수익 배분 조건을 고려하여 해당 콘텐츠

의 제작을 수탁했음에도 불구하고 2차 이용을 관리하는 위탁자가 수탁자의 2차 이용 요청·제안에 대해 합리적인 이유 없이 응하지 않을 경우

(수탁자가 콘텐츠를 제작하는 과정에서 발생한 거래 대상 이외의 성과물 등의 권리의 양도 및 2차 이용 제한 등)

- ① 수탁자가 거래 대상인 콘텐츠를 제작하는 과정에서 발생한 해당 콘텐츠 이외의 성과물 등에 대해 수탁자에게 권리가 발생하는 경우에 위탁자가 위에서 소개한 경우와 유사한 행위를 하는 경우

〈법에 위반되지 않는 경우〉

콘텐츠에 관한 권리의 양도 또는 2차 이용의 제한에 대한 대가를 별도로 지불하고, 해당 대가를 포함한 형태로 대가에 관한 협상을 하고 있는 것으로 인정되는 때에는 우월적 지위의 남용 문제가 되지 않는다. 단, 이러한 경우에도 콘텐츠에 관한 권리의 양도 등에 대한 대가가 부당하게 낮은 경우와 콘텐츠에 관한 권리의 양도 등을 사실상 강제하는 경우 등 수탁자에 대하여 부당하게 불이익을 주는 경우에는 거래상 지위의 남용으로 문제될 수 있다.

● 기술자료 제공 강요행위

〈법에 위반되는 경우〉

- ① 정당한 사유 없이 공급사업자의 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 강요하는 행위
- ② 취득한 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 유용하는 행위

프리랜서 공정거래를 위한 자체 점검사항[요약]

구분	점검사항
계약체결 및 사업자선정 관련 사항	- 표준계약서, 표준약관 등 공정계약서를 채용하였는가? - 거래조건에 대한 명시 및 충분한 설명을 하였는가? - 계약의 체결방식: 하도급계약서의 서면을 교부하였는가?
거래조건 관련 사항	- 유사 콘텐츠에 대한 통상적인 거래대금보다 현저히 낮은 대가를 요구하였는가? - 검수기준을 변경한 일이 있는가? - 검수기준 변경은 몇 차례 있었는가? - 검수기준 변경을 위한 불가피한 사유가 있었는가?
대금관련 사항	- 대금지급을 지연하였는가? - 대금감액을 요청하였는가? - 대금지급지연이나 감액을 한 불가피한 사유가 있었는가? - 하도급계약의 경우 납품단가의 인상에 따른 제작자의 조정협약에 응하였는가? - 현금결제는 비중은 어떠한가?
계약이행 관련 사항	- 계약당사자 일방으로 부터 특정 제품에 대한 물품구입 요청이 있었는가? 횡수 콘텐츠 계약과의 관련성, 해당 제품의 제작자와 요청자의 관계 등 - 협찬금 등 경제상 이익의 제공 요청이 있었는가? 횡수, 경제상 이익제공의 사유 및 요청받은 사업자에 대한 반대급부 여부

납품관련 사항	• 지연이자의 연간요율(법정이자와의 차이)은 어떠한가? • 발주를 취소한 일이 있는가? 또한 그에 대한 불가피한 사유가 있었나? • 완성된 목적물의 수량을 거부하였는가? 또한 그에 대한 불가피한 사유가 있었나? • 재작업을 요구한 일이 있었나? 또한 그에 대한 불가피한 사유가 있었나? • 사후적인 거래정지나 수량삭감을 한 일이 있었나? 또한 그에 대한 불가피한 사유가 있었나?
지적재산권 (저작권 등) 관련 사항	• 계약서에 저작권 등 지적재산권 관련한 합의가 있었나? • 콘텐츠 관련 기술자료 등 저작권 제공을 요구하였나? • 콘텐츠 관련 기술자료를 유용한 일이 있는가? • 콘텐츠관련 저작권은 누구에게 귀속되는가? • 저작권 양도에 따른 수익배분 비율은 적절한가?



경기도 프리랜서 공정 가이드라인

발행일	2021.10.
판명	초판 1쇄
발행처	경기도
발행부서	경기도 공정국 공정경제과
주소	경기도 수원시 팔달구 효원로 1 (매산로 3가) 경기도청 제 3 별관 공정경제과

디자인인쇄	더조은프린트 1544-1466
-------	------------------

경기도 프리랜서 공정 가이드라인 전문은 경기도 공정거래지원센터 홈페이지
(<https://www.gg.go.kr/ubwutcc-main>) 에 게재되어 있습니다 .